

posibilidad de reconocer el derecho subjetivo en esta o en aquella posición garantizada al individuo por el ordenamiento jurídico, cuanto por la dificultad formal de advertir cómo el mismo nombre pueda aplicarse a la norma, que es siempre un límite, y al poder, que se presenta como una expansión de la actividad individual, y por la ulterior y más sustancial dificultad para determinar cómo, de normas que no pueden contener más que órdenes y prohibiciones, nacen facultades y poderes individuales.

Pero el problema se resuelve fácilmente si se acepta la definición de PEROZZI<sup>8</sup>, según la cual el derecho subjetivo es "la facultad concedida a un individuo por el derecho objetivo, para exigir de otro determinada conducta". Esta definición se entiende en el sentido de que en ciertas hipótesis corresponde a cada uno de los interesados el control sobre el cumplimiento de las normas establecidas en su favor; en tales hipótesis bien puede decirse que la actividad normativa propia de la sociedad se trasfiere al individuo, de suerte que la norma misma, el derecho, se convierte de general en individual, de objetivo en subjetivo.

Es fácil ver cómo ocurre esto si se considera el fundamento y el modo de ser de los diversos preceptos jurídicos. Por ejemplo, el precepto que nos prohíbe matar, establecido por todo país civilizado en salvaguardia de uno de los intereses fundamentales de la comunidad, se halla, en su ejecución, permanentemente controlado por el Estado mismo, de modo que quienquiera que sea muerto y aun cuando ningún otro individuo se considere afectado, un órgano del Estado (*quaestores parricidii*, ministerio público, etc.), o un ciudadano como tal (acción popular), promueve la aplicación de la sanción. Aquí la norma de derecho objetivo permanece como tal, sin subjetivarse nunca. En forma muy diversa funciona el precepto que nos impone pagar las deudas. La seguridad del crédito representa, sin duda, un elevadísimo interés social, por lo que es objeto de normas jurídicas minuciosas; pero el interés social está solamente en que los acreedores puedan contar con el concurso del Estado para exigir sus créditos de los deudores, y no precisamente en que se satisfaga el crédito particular de A o B respecto de C o D. Establecido esto, es suficiente que se pongan a disposición de los acreedores los medios necesarios para recurrir a los órganos a quienes corresponde verificar

<sup>8</sup> Ist., 2ª ed., I, p. 81.

el eventual incumplimiento y aplicar la debida sanción: si los acreedores no quieren servirse de estos medios, peor para ellos. En sustancia, son los interesados los que deben pretender de la contraparte la conducta que la norma describe: he aquí que la norma no rige solamente como norma del derecho objetivo, sino como *subjetivada*, trasformada en derecho subjetivo. Las cosas no cambian en los llamados derechos subjetivos absolutos, que parecen poner a su titular en relación directa con determinado bien, fuera de toda relación con los coasociados (por ej., el derecho de propiedad): aquí también hay una pretensión a la conducta de otro, pero mientras los derechos relativos (como los de crédito, ya descritos) se dirigen contra determinadas personas, obligadas las más de las veces a una conducta positiva (por ej., la prestación de una suma o la ejecución de una obra), los derechos absolutos se dirigen contra todos los coasociados, imponiéndoles una conducta negativa (todos deben abstenerse, por ejemplo, de cualquier ingerencia en mi cosa). Ni siquiera debe causar sorpresa la concurrencia que a veces se produce entre los órganos del Estado y el particular, al hacer valer intereses que son, a la vez, colectivos e individuales: aquí se trata sustancialmente del concurso de dos intereses, y por lo tanto de dos normas, puramente objetiva una, subjetivada la otra.

Frente a la norma, sea o no subjetivada, se halla quien en virtud de ella está obligado a cierto comportamiento; considerando el conjunto de los individuos a los que se dirige la norma, en el sentido de que ésta tendrá aplicación respecto de cualesquiera de entre ellos en quienes se verifiquen sus presupuestos, dichos individuos se llaman *destinatarios* de la norma misma; en cambio considerando la limitación en que incurre la libertad de cada uno cuando los presupuestos se hayan verificado a su respecto, se habla de un *deber jurídico* que recae sobre él. No se concibe sociedad humana en la que cada asociado no esté sujeto a un número infinito de deberes jurídicos, aun cuando muchos deberes, correspondientes a derechos absolutos de otros, los advirtamos solamente en las ocasiones, más o menos raras, en que estamos tentados de violarlos. Frente a la propiedad, a la libertad y a la vida ajenas, cada uno de nosotros tiene tantos deberes negativos cuantos son los objetos apropiados y no nuestros, cuantos son los coasociados; pero la observancia de estos deberes, al entrar en la esfera normal de nuestra actividad tiene lugar automáticamente.

Y lo mismo puede decirse de algunos de los derechos subjetivos correspondientes (derecho al honor, a la integridad física, etc.), derechos que cada uno advierte tener solamente si los siente violados o en vías de serlo. Más vivamente sentimos aquellos derechos y deberes que nos crean una posición anormal, ocasionando un desequilibrio en beneficio o en perjuicio nuestro; de ahí la preponderancia que espontáneamente adquieren en el pensamiento de quienquiera que medite sobre derechos y deberes, las relaciones de crédito y de deuda.

La relación que existe entre el titular de un derecho subjetivo y el sometido al deber jurídico correspondiente, toma el nombre de *relación jurídica*. Considerados como términos de esta relación, el titular del derecho (acreedor, propietario, etc.) se llama *sujeto activo*, y el sometido al deber jurídico (deudor, no propietario, etc.), *sujeto pasivo*.

La norma jurídica, por lo común, es abstracta, es decir, rige para todos los casos que presenten o puedan presentar en lo futuro ciertas características; su aplicabilidad en concreto depende, pues, de la verificación de los presupuestos de hecho que integran, caso por caso, aquellas características. Ahora bien; todo hecho que aisladamente o combinado con otros, concomitantes o sucesivos, constituye un supuesto para la aplicación de una norma de derecho, se llama *hecho jurídico*<sup>4</sup>. Los hechos de esta especie son infinitos y, en consecuencia, difíciles de clasificar; pero, puesto que

<sup>4</sup> Ocurre a veces que la norma no considere directamente un hecho determinado como presupuesto de su actuación, pero que llegue al resultado suponiendo que en lugar del hecho realmente acontecido se haya producido otro ya previsto por una precedente norma, de manera que ésta se aplique automáticamente. Cuando esto sucede, se habla de *ficción jurídica* (*fictio iuris*). El derecho romano usó con amplitud de este medio en la época en que el derecho pretorio fué corrigiendo las asperezas del derecho civil; el medio era apropiado, porque no pudiendo el pretor modificar las relaciones del *ius civile*, la vía mejor para proteger relaciones nuevas era, precisamente, hacer que el juez se comportase como si se hubieran verificado los presupuestos que el derecho civil exigía. Es lo que ocurre, por ejemplo, en la *actio Publiciana*: quien ha recibido una *res Mancipi* sin acto solemne, no es propietario de ella, y solamente puede llegar a serlo mediante el transcurso de cierto tiempo, *per usucapionem*; pero el pretor, que considera oportuno proteger al adquirente desde el primer momento, le concede una acción, en virtud de la cual el juez debe fingir cumplida la usucapción (ver más adelante, p. 207; y para las acciones ficticias en general, ps. 145 y ss.).

Donde falta aquella pluralidad de sistemas jurídicos que es la característica del derecho romano clásico, el recurso de las ficciones debe

la pertenencia o no del hecho al espíritu humano tiene capital importancia, no es inoportuna la distinción entre hechos *alógicos* (= no espirituales) y *lógicos*. Hechos jurídicos *alógicos* son, por ejemplo, la separación del fruto de la planta, presupuesto del nacimiento de un nuevo derecho de propiedad sobre la nueva cosa que adquiere individualidad propia; el nacimiento de un hombre libre, presupuesto de los derechos de personalidad que el nuevo sujeto adquiere inmediatamente, como de los varios derechos patrimoniales que en las diversas circunstancias pueden tener por sujeto (activo o pasivo) a su persona; la muerte, presupuesto de la apertura de la sucesión; el granizo, cuando origina para una compañía de seguros la obligación de pagar la indemnización; y se podría continuar hasta lo infinito. En cuanto a los hechos jurídicos *lógicos* es fácil subdistinguirlos según pertenezcan a la inteligencia o a la voluntad humana. Entre los primeros se halla, por ejemplo, el conocimiento que alguno tenga o no de determinadas circunstancias de hecho, como del derecho de un tercero sobre la cosa de que entra en posesión, o del delito que su esclavo comete o está por cometer.

Sin embargo, la mayor importancia en el orden de los hechos jurídicos corresponde a aquellos que son propios de la voluntad humana (*actos*). De ellos se puede intentar (y se ha intentado muchas veces) una clasificación completa; pero a los fines de nuestro estudio basta poner de relieve sus dos categorías más características, que son:

a) el *acto ilícito*, violación de la norma jurídica primaria y consecuentemente presupuesto de la aplicación de la sanción;

b) el *negocio jurídico* o *acto jurídico*, declaración de voluntad emitida con el fin de alcanzar ciertos resultados prácticos y reconocida por el derecho objetivo que hace derivar de ella, conforme a los fines de los declarantes, la creación de nuevas relaciones jurídicas, o la modificación o extinción de relaciones existentes.

---

casi siempre ser evitado: en nuestro ordenamiento jurídico, por ejemplo, una ley nueva no está nunca constreñida a incluir ficticiamente los presupuestos nuevamente reconocidos entre los ya conocidos. Sin embargo, el medio técnico de la ficción no ha agotado toda su utilidad, ya que aun es a veces necesario para expresar en forma simple y plástica todo un complejo de reglas: el caso más típico es el de las personas jurídicas (sobre el cual, cf. ps. 75 y ss.).

De una categoría a la otra, la relación entre la voluntad individual y la estatal se plantea en términos opuestos: de conflicto en el primer caso, de cooperación en el segundo. Y ambas encuentran aplicación en cada parte del derecho: acto ilícito es tanto el delito reprimido por la norma del derecho penal público, como el reprimido en los medios del proceso privado, como la actividad desarrollada por los órganos del Estado fuera de los límites de su competencia constitucional, aunque falten eventualmente los medios de represión; acto o negocio jurídico en sentido lato es tanto el contrato entre particulares como la sentencia o el acto administrativo o la ley. Sobre los actos ilícitos, en los límites en que interesan al derecho privado, se trata en otra parte de esta obra, y precisamente en materia de obligaciones (cap. XVI); de los negocios jurídicos se trata en todas partes, pero algunos principios comunes serán desarrollados en esta parte general (cap. III).

## § 2. CONCEPTOS Y TERMINOLOGÍA DE LOS ROMANOS

*Ius, iuris praecepta. Ius y fas.* La terminología del negocio jurídico.

También entre los romanos la palabra *ius* es usada indiferentemente, tanto en sentido objetivo como en sentido subjetivo; es más, aquella sustancial identidad de derecho objetivo y subjetivo que hemos puesto en claro, se expresa en varios lugares de nuestras fuentes con particular vivacidad. Considérense, por ejemplo, aquellos versículos de las XII Tabas en los cuales, para afirmar la eficacia de los más antiguos negocios formales, se usa la expresión *ita ius esto*<sup>5</sup>; traduciendo "sea tal el derecho", no podemos entender esta palabra ni en sentido estrictamente subjetivo (porque, sin duda, la expresión quiere dar particular relieve también al deber jurídico) ni en sentido estrictamente objetivo (porque la norma abstracta está ya en la ley, no surgirá del hecho del particular), sino en un sentido dinámico que toma a la norma en el acto mismo en que se subjetiva. Por otra parte, también entre los juristas clásicos el significado más amplio y más difundido de

<sup>5</sup> Si nexum faciet mancipiumque, uti lingua nuncupassit, ita ius esto. Uti legassit super pecunia tutelave suae rei, ita ius esto.

*ius publicum* (cfr. p. 9, n. 5) es el de derecho que emana del Estado, norma objetiva que los particulares no pueden derogar; su antítesis es, precisamente, aquel *ius* que cobra existencia, caso por caso, con el negocio jurídico.

Sin embargo, el espíritu de la jurisprudencia romana, más analítico que sintético, más práctico que teórico, no podía llegar a una definición del derecho ni en uno ni en otro de sus significados. Esos conceptos generales que hallamos expuestos a la cabeza de las diversas partes de la compilación justiniana, y de los cuales es muy difícil establecer si derivan de los juristas clásicos o de tardías glosas bizantinas, permanecen en el límite entre la reflexión científica y la mera aspiración ética: así la clasificación de los tres *iuris praecepta* (*honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere*: D. 1, 1, 10 § 1); la definición de la jurisprudencia (impropiamente denominada *ius*) como *ars boni et aequi* (fr. 1 pr. h. t.) con el consecuente discurso retórico sobre la nobleza de la profesión de jurista (§ 1 h. t.); la ulterior definición de la jurisprudencia misma como *divinarum atque humanarum rerum notitia, iusti atque iniusti scientia* (D. 1, 1, 10 § 2).

Más que persistir en la inútil tentativa de extraer de estas frases vagas un sistema de doctrinas, es útil recordar que en los comienzos de la evolución del derecho romano (como, por lo demás, también en otros ambientes históricos) es sumamente imperfecta la diferenciación entre los diversos sistemas de reglas de conducta. Esto vale especialmente para las relaciones entre derecho (*ius*) y religión (*fas*); no porque se haya demostrado (aunque sobre ello se suela hablar desde hace tiempo) el origen religioso de muchas instituciones jurídicas, sino porque, mientras la eficacia de la palabra que crea y defiende al derecho subjetivo está controlada por los ministros de la religión (pontífices), las relaciones con los dioses son concebidas a menudo bajo forma jurídica. Por otra parte, también el uso ambiguo de la palabra *mores*, en la que se confunden las costumbres normativas y las normas de cortesía política y social, atestigua la maraña indistinta en que se presentaban las diversas reglas de conducta al espíritu de los antiguos. Pero todo esto pertenece a la época primitiva de la historia del derecho romano; ya en los últimos siglos de la República las normas jurídicas aparecen netamente diferenciadas de todas las demás, objeto de estudio, de enseñanza y de elaboración científica propias.

No nos esforzaremos, después de cuanto hemos ya observado, en buscar en la terminología romana expresiones correspondientes a las de deber, relación, hecho jurídico; ni siquiera podemos contar con una definición y una teoría general del negocio jurídico. Sin embargo, para esta última parte hay, por lo menos, una dirección terminológica que corresponde a la nuestra y que anticipa, más bien, la amplísima concepción del acto jurídico precedentemente aludida: el verbo *agere* y sus derivados —*actio*, *actus*, *actum*— se refieren a menudo, y con tanta mayor frecuencia cuanto más se remonta hacia lo pasado, a toda declaración individual dirigida a constituir o conservar un derecho. Pero ésta es más bien una espontánea derivación del uso de ese verbo en el sentido de “representación”, que el resultado de una reflexión científica; tanto es así que no pocos negocios jurídicos, especialmente el testamento, parecen refractarios a ser subsumidos en esas denominaciones, y la principal de ellas, *actio*, bien pronto se circunscribió (esta vez con valor técnico) al campo del procedimiento (cfr. cap. iv)<sup>6</sup>.

### § 3. LAS DIVERSAS CLASIFICACIONES ROMANAS DEL DERECHO OBJETIVO

Clasificaciones de carácter histórico o formal: a) *ius* y *lex*; b) *ius civile* y *ius honorarium*; c) *ius ex scripto* y *ex non scripto*; d) *ius civile*, *ius gentium*, *ius naturale* (la *aequitas*). Clasificaciones sistemáticas: e) *ius publicum* y *ius privatum*; f) *ius commune* y *ius singulare*: *beneficia* y *privilegia*.

Gran parte de las clasificaciones introducidas por la jurisprudencia romana en el sistema de las normas jurídicas, se refiere a las diversas fases de la evolución del derecho romano; su descripción constituye, pues, parte fundamental del curso de historia del derecho romano, y lo necesario para los fines de una primera orientación ya se ha dicho en la *Introducción*. Por lo tanto, no hay razón para insistir aquí sobre las contraposiciones entre *ius* y *lex* y entre *ius civile* y *honorarium* (o *praetorium*)

<sup>6</sup> Cfr. MITTELS, *Römisches Privatrecht*, I, ps. 155 y ss., y aquí, ps. 153 y ss., para todos los otros términos más o menos generales que en las distintas épocas han servido para abrazar vastos grupos de negocios.



(cfr. ps. 2 y ss.), ni sobre el aporte que suministraron a la evolución del derecho durante el Principado los senadoconsultos y (en medida cada vez más imponente cuanto más se avanza hacia el Bajo Imperio) las constituciones imperiales.

Quizá los últimos juristas republicanos, en un momento en que el derecho vigente se presentaba a su espíritu como esencialmente constituido por el antiguo *ius civile* y por las *leges comiciales*, consideraron que podían aplicar también a Roma la distinción que los filósofos griegos habían establecido entre las leyes escritas (*νόμοι ἔγγραφοι*) y las no escritas (*νόμοι ἄγραφοι*). Por eso en algunos pasajes de la jurisprudencia imperial, inspirados seguramente en aquellos ilustres ejemplos, se dice que la parte del derecho no sancionada en las leyes (ni en otras disposiciones tomadas por los órganos de la ciudad) *sine scripto in sola prudentium interpretatione consistit* (POMPONIO, D. 1, 2, 2 § 12; cfr. *ibíd.*, § 5); y en un pasaje de las Instituciones de ULPIANO (D. 1, 1, 6 § 1), que un sector de la doctrina moderna considera interpolado<sup>7</sup>, se dice que *ius nostrum constat aut ex scripto aut sine scripto, ut apud Graecos τῶν νόμων οἱ μὲν ἔγγραφοι, οἱ δὲ ἄγραφοι*.

De todas maneras, el *ius ex non scripto* que se desarrolla a través de la *interpretatio prudentium*, no puede identificarse con la que nosotros llamamos costumbre y que es "la observancia constante y uniforme de una regla de conducta cumplida por los miembros de una comunidad social con la convicción de su correspondencia con una necesidad jurídica"<sup>8</sup>. El derecho romano es, en efecto, hasta la época a que puedan remontarse nuestros conocimientos, una técnica delicada de la cual solamente pocos hombres (originariamente, pocos sacerdotes) tienen el secreto; de modo que la opinión pública, naturalmente capaz de plantear la exigencia de que se logren algunos resultados, debe remitirse al juicio de los expertos acerca de la posibilidad o no de adaptar los módulos de los actos jurídicos o de las acciones primordiales en la medida suficiente para producir los nuevos efectos. Tampoco el jurista inventa sus medios técnicos según los dictados de la equidad, sino que se limita (por lo menos en su intención y en las convicciones populares) a escrutar el modo de ser de esos

<sup>7</sup> Cfr., especialmente, PEROZZI, *Ist.*, 2ª ed., I, ps. 41 y ss.; y STEINWENTER, *Studi Bonfante*, II, ps. 433 y ss.

<sup>8</sup> DE RUGGIERO, *Ist. di dir. civ.*, 3ª ed., I, p. 81.



antiguos módulos para verificar si en ellos mismos existe o no la deseada adaptabilidad.

En cambio, la doctrina de la costumbre se desarrolla plenamente en la época posclásica, correlativamente con el principio según el cual la ley responde al arbitrio del príncipe y como correctivo de dicho principio. Especialmente muchas materias que las leyes imperiales no habían reglado, y que en las diversas provincias orientales no podían someterse fácilmente al régimen fijado en el derecho romano antiguo y clásico, son abandonadas a los usos generales y locales. Y éstos entonces sólo tienen derecho al respeto cuando, por una parte, la observancia es uniforme (especialmente cuando se apoya en la autoridad de juicios ya pronunciados), y, por la otra, se cumpla con *opinio necessitatis*, es decir, con la persuasión de seguir normas jurídicamente obligatorias<sup>9</sup>. En este nuevo sentido, la contraposición entre *ius ex scripto* y *ex non scripto* fué establecida como base de la compilación justinianeá, sobre todo a través de las Instituciones imperiales (I, 2, § 3 y ss.); pero con tanta divergencia respecto del uso clásico, que ya los *responsa prudentium* son considerados como una de las tantas categorías de *ius ex scripto* procedentes de la antigüedad clásica.

Más amplia consideración exige la distinción entre *ius civile*, *ius gentium*, *ius naturale*. En verdad, la doctrina clásica, tantas veces recordada en las obras ciceronianas y expuesta con vivacidad e insistencia por GAYO, contrapone el *ius civile* solamente al *ius gentium*, llamado también indistintamente *ius naturale*<sup>10</sup>. La antítesis está descrita, en el pasaje fundamental de GAYO (I, 1), como el resultado de una especulación doctrinal; se observa que mientras cierto grupo de normas es característico de una ciudad determinada, otras normas, más directamente sugeridas por la razón

<sup>9</sup> Sobre el ulterior problema de si la costumbre puede derogar la ley, cfr., entre los últimos, *La desuetudine della legge*, en "Arch. Giur.", 102, 1929, ps. 3 y ss., y STEINWENTER, loc. cit.

<sup>10</sup> No nos ocupamos aquí de aquella menos frecuente acepción por la cual *ius gentium* designa las normas aplicadas en el mundo antiguo a las relaciones entre los Estados, como el derecho de guerra, de presa, de embajada. Esta acepción es extraña a las fuentes jurídicas; también en D. 41, 1, 5 § 7, figura el primero entre los dos significados privatísticos que veremos por ahora. Sobre el tema en examen véase ahora la docta investigación de G. LOMBARDI, *Sul concetto di ius gentium*, Roma, 1947.

natural (*naturalis ratio*), son igualmente observadas en todos los pueblos (mejor dicho, entre todos los pueblos que han alcanzado cierto grado de civilización). Coherentemente con esta definición, GAYO hace derivar de la *naturalis ratio*, como instituciones que rigen *omnium civitatum iure*, la tutela de los impúberes (I, 189), la adquisición de la propiedad por *occupatio bellica* (II, 69) o por aluvión (II, 70), y otras semejantes. Así entendida, la antítesis tendría muy escasa importancia y se reduciría a una mera y estéril verificación de hecho; si la tutela es una institución común, supongamos, al derecho romano y al griego, ello sólo demuestra que la elemental exigencia social de donde procede la institución, era igualmente sentida tanto por uno como por el otro pueblo.

Pero el nombre de *ius gentium* es adoptado por los juriscultos para expresar también una comunidad de derecho. Al respecto, es fundamental el pasaje de GAYO, III, 93, en el que, apenas descrito en sus distintas formas el contrato verbal típico, la *stipulatio*, se agrega: "*Sed haec quidem verborum obligatio dari spondes? spondeo propria civium Romanorum est; ceterae vero iuris gentium sunt, itaque inter omnes homines, sive Romanos sive peregrinos, valent...*". Y en el § 94: "*Unde dicitur uno casu hoc verbo (spondeo) peregrinum quoque obligari posse...*". Aquí no se afirma que la estipulación sea un producto de la razón natural y que por ello haya surgido espontáneamente en todos los pueblos (lo que sería falso, tratándose de una institución netamente romana); en cambio, se afirma que las estipulaciones contraídas con verbo diverso de *spondeo* (y en el caso especial del § 94 también las contraídas con ese verbo) generan obligaciones válidas también entre los romanos y los extranjeros. El mismo significado tienen las afirmaciones relativas al contrato de sociedad, que es *iuris gentium* y, en consecuencia, *inter omnes homines naturali ratione consistit* (GAYO, III, 154), a la compraventa, que es *iuris gentium*, *et ideo consensu peragitur* (PAULO, D. 18, 1, 1 § 2), a la locación-conducción, que también *consensu contrahitur, cum naturalis sit et omnium gentium* (id., D. 19, 2, 1).

Los casos recordados y algunos otros análogos, son el resultado de un desarrollo histórico, dirigido a crear medios adecuados a la contratación entre los romanos y los extranjeros. En efecto, las relaciones comerciales que se establecieron entre Roma y los grandes mercados del Mediterráneo en la época que siguió

a la primera guerra púnica, no habrían podido llevarse a la práctica, de seguir el rígido criterio primitivo según el cual toda norma jurídica sólo contemplaba a los ciudadanos; ocurría que algunos negocios jurídicos propios de un país, se hicieran lícitos también para los extranjeros, que otros fueran creados o adaptados de manera que resultaran accesibles a contratantes de diversas nacionalidades, y que en cada ciudad, magistrados especiales tuvieran jurisdicción sobre las contrataciones así realizadas. Siguiendo el ejemplo que habían dado ya las ciudades griegas en sus relaciones recíprocas, se introdujo también en Roma, alrededor del 240 a. C., junto al magistrado competente en las relaciones entre los ciudadanos (*praetor urbanus*), un nuevo pretor *qui inter cives et peregrinos ius dicit*; ante él hallaron reconocimiento los contratos consensuales de compraventa, de locación, de sociedad, de mandato, las estipulaciones entre romanos y extranjeros, etc.<sup>11</sup>.

Los contratos consensuales y las otras instituciones surgidas del comercio internacional fueron admitidos después también en las relaciones entre los ciudadanos<sup>12</sup>.

La segunda y más práctica acepción de la contraposición entre *ius civile* y *ius gentium* predominó no sólo hasta que Roma se halló frente a otros países independientes, sino también cuando estos países fueron reducidos a provincias romanas y hasta que éstas continuaron gozando de sus propios ordenamientos jurídicos. Pero después de la constitución caracalliana del 212 —que al tiempo que concedía a todos los súbditos la ciudadanía romana, los obligaba a vivir conforme al derecho de Roma— la antítesis *ius civile-ius gentium* se mantuvo sólo en el sentido más abstractamente doctrinal, tan caro para las escuelas posclásicas en sus tendencias hacia la abstracción (cfr. p. 5).

Y es probable que precisamente en época posclásica se haya cumplido el desarrollo que trasformó la bipartición en triparti-

<sup>11</sup> Sobre el problema de la medida en que las normas del derecho griego hayan podido por esta vía ser imitadas en Roma, véase *Storia*, 5ª ed., ps. 148 y ss.

<sup>12</sup> En este sentido se habla de una recepción del *ius gentium* en el *ius civile*: expresión un tanto incorrecta, porque, en el sentido de la antítesis que ahora ilustramos, aquellos contratos permanecen siempre *ius gentium*. Ellos pertenecen al *ius civile*, en cambio, en el sentido en que esta expresión se contrapone a *ius honorarium*: la relación que muchos escritores se complacen en establecer entre la actividad integrativa y correctiva ejercida sobre el sistema jurídico por el pretor (urbano) y el desarrollo del *ius gentium* no existe en realidad.

ción. Ya entre los partidarios de la bipartición descrita, GAYO especialmente, deriva que, de la conexión que se establece entre *ius gentium* y *naturalis ratio*, se le atribuya a aquél el nombre de *ius naturale* (cfr., por ejemplo, GAYO, I, 156; II, 65, 73). Pero en ciertos pasajes de la compilación justiniana, y sobre todo en varios fragmentos que llevan el nombre de ULPIANO, el *ius naturale* figura como un tercer término de la clasificación, al lado de los dos de la doctrina ciceroniana y gayana. La contradicción en que se hallan estos textos con toda la tradición científica precedente, ha llevado a la hipótesis de su interpolación justiniana<sup>13</sup>; pero tal vez es más probable la opinión, sugerida por la localización de la doctrina en la obra de algunos juristas solamente, de que se trate más bien de glosas aportadas a los escritos de jurisprudencia por estudiosos prejustinianos, y trasladadas junto con el texto a la compilación<sup>14</sup>. Como quiera que sea, aun si —como no hay por qué excluirlo— uno y otro texto estuvieran intactos, el concepto de *ius naturale* que se expresa no es constante. En el pasaje que debería ser fundamental (D. 1, 1, 1 § 3), el *ius naturale* es considerado como parte del sistema jurídico vigente, parte que debería subsistir luego de eliminadas tanto las normas propias de cada *civitas* (*ius civile*) como las comunes a todos los pueblos (*ius gentium*): para hallar tal residuo se ha debido recurrir al absurdo de una comunidad de derecho entre hombres y bestias, y

<sup>13</sup> Así, PEROZZI, *Ist.*, 2ª ed., I, ps. 91, n. 2, y 100, n. 3; con él MITTEIS, I, p. 63 en n., y para el texto fundamental BESELER, *Contributi alla critica delle fonti giuridiche romane* [*Beiträge zur Kritik der röm. Rechtsquellen*], III, p. 131.

<sup>14</sup> Opinión presentada por ROTONDI en algunos apuntes sobre los *Precedenti scolastici delle riforme di Giustiniano* (*Scr. giur.*, I, p. 443). También si, como agudamente se ha señalado, filósofos contemporáneos de Ulpiano habían ya teorizado alguno de los aspectos bajo los cuales él parecería describir el *ius naturale*, esto no prueba que tales especulaciones hayan podido ser aceptadas por jurisconsultos tan realistas y sagaces. La simpatía posclásica por el derecho natural puede dar razón también de la contradicción entre estos glosemas y otros, más o menos contemporáneos, que todavía equiparan *ius naturale* y *ius gentium* (*Inst.*, 2, 1 § 11: *iure naturali* [quod, sicut diximus, appellatur *ius gentium*]; § 41: *iure gentium* [id est *naturali*]): las glosas provienen de diversas manos y no es extraño que en ellas se proyecten puntos de vista divergentes. Sobre el tema, ver ALBERTARIO, *Sul concetto di ius naturale*, en "Rend. Ist. Lomb.", 57, 1924, ps. 168 y ss., ahora en *Studi di dir. rom.*, 5, Milano, 1937, ps. 277 y ss.

definir al derecho natural como aquel *quod natura omnia animalia docuit*, agregando una ejemplificación completamente digna de la definición. En otros lugares el derecho natural se presenta, en cambio, como una exigencia de razón no puesta en práctica en el ordenamiento vigente; así, por ejemplo, en materia de esclavitud, cuando se considera esta institución, propia de la antigüedad, conforme al *ius gentium* pero *contra naturam* (D. 1, 5, 4 § 1), "*utpote cum iure naturali omnes liberi nascerentur*" (D. 1, 1, 4). En esta última dirección de pensamiento es fácil reconocer los rastros del concepto de la φύσις, propio de la filosofía griega (φύσει πάντες ἐλεύθεροι), y al mismo tiempo la influencia de la enseñanza cristiana, que predica la igualdad entre los hombres<sup>15</sup>.

Otras distinciones son de naturaleza netamente sistemática. Tal la que se establece entre *ius publicum* y *ius privatum*, considerada fundamental en un celeberrimo texto de ULPIANO, D. 1, 1, 1 § 2: "*Publicum ius est quod ad statum rei Romanae spectat*,

<sup>15</sup> En cierta conexión con los conceptos de *ius gentium* y de *ius naturale* está también, por lo menos en alguna de sus aplicaciones, la doctrina de la *aequitas*. Esta doctrina, que expresa principalmente la adecuación de la norma a las exigencias de las relaciones particulares, tuvo quizá su primer punto de apoyo en ciertas fórmulas procesales, llamadas precisamente *in bonum et aequum conceptae*, que imponían al juez fijar el monto de la condena *ex bono et aequo* o *in quantum aequius melius iudici visum fuerit*, es decir, teniendo en cuenta todos los elementos del caso concreto. Pero en el lenguaje de los juristas el nombre de la *aequitas* y el adjetivo *aequus* fueron también frecuentemente usados para valorar la correspondencia de las instituciones con el sentimiento jurídico prevaliente: así se dice que esta o aquella cláusula del Edicto pretorio *habet in se aequitatem*, y en general se contrapone la equidad del pretor a la rigidez del *ius civile*. En fin, este sentimiento jurídico, piedra de toque de las instituciones vigentes, estaba referido a aquella misma *naturalis ratio* de donde se habían hecho derivar las normas del *ius gentium*: de aquí la frecuente mención de una *aequitas naturalis*, contrapuesta a la *civilis*. De todos modos, corresponde observar que, a la par de la *naturalis ratio* justificativa del *ius gentium*, tampoco la *naturalis aequitas* era invocada por los clásicos más que como fundamento de instituciones positivas, nunca como razón de duda acerca de la conveniencia de las normas vigentes. Y todavía hay que señalar que la tendencia a limitar el alcance de los principios de derecho en nombre de una equidad cerebrina, extraña a las normas positivamente dictadas, es vivacísima en el derecho justinianeo (cfr. PRINGSHEIM, *Ius aequum und ius strictum*, en la "Rev. Fundac. Savigny", 4, 1921, ps. 643 y ss.). Pero de admitir esto a afirmar, como hace BESÉLER (rev. cit., 45, 1925, p. 455), que "la palabra *aequitas* está borrada del vocabulario de la jurisprudencia clásica", hay mucha distancia.

privatum quod ad singulorum utilitatem"<sup>16</sup>. Parece, pues, que para establecer la pertenencia de una norma a cualquiera de las dos ramas, es necesario determinar si ella rige en interés de la colectividad en cuanto tal o en interés de los individuos. Un criterio que si bien a primera vista parece decisivo, no puede aceptarse, sin embargo, sin alguna previa dilucidación: en efecto, el concepto mismo del derecho, como complejo de normas que tienen por fin la conservación y el perfeccionamiento de una sociedad, impide que formen parte de él disposiciones desprovistas de interés social; mientras que, a la inversa, no hay norma implantada en el interés colectivo, de la que los particulares no obtengan algunas ventajas a veces inestimables (piénsese en las normas que organizan la constitución política, o en la que prohíbe el homicidio, etc.). Sólo es indiscutible el predominio del interés colectivo en ciertos casos, y el del interés individual en otros; si predomina el primero, por ejemplo en las normas que se acaban de citar, de tal modo que pueda decirse que la ventaja obtenida por los particulares es indirecta o casi refleja, el segundo se halla en primera línea en las normas que organizan la propiedad, el crédito, las sucesiones. Como consecuencia de ello, vemos verificarse en todas las normas de derecho privado esa situación que da lugar al derecho subjetivo y que consiste en ponerse a disposición del particular interesado; mientras que las normas del derecho público permanecen, por lo común, meramente objetivas (cfr. p. 20): entre nosotros no faltan los casos en que también para normas de esta última especie se verifica el proceso de subjetivación; pero se trata de un producto de la concepción moderna de las relaciones entre Estado e individuo, concepción inaccesible al pensamiento romano.

También bajo otros aspectos el mundo antiguo presenta, mucho más netamente definida que en el mundo moderno, la línea de demarcación entre las dos ramas del derecho. Para nosotros, decir que una norma jurídica rige en interés del Estado no expresa todavía aquel inmediato destino a la utilidad colectiva, de

<sup>16</sup> Para la interpolación de la frase que sigue ("*sunt enim quaedam publice utilia, quaedam privatim*"), afirmada por primera vez por PERROZZI, ver últimamente STEINWENTER, *Festschrift Koschaker* (1939), I, ps. 84 y ss.

donde tomamos la calificación de norma de derecho público; por el contrario, el Estado se nos presenta, además de su manifestación en el poder soberano, también dirigido a la prosecución de actividades industriales y comerciales, no diversas de aquellas a que normalmente se dedican los particulares. En la segunda hipótesis, el hecho de que el Estado sea parte de la relación no impide que ésta continúe siendo de derecho privado. Para el derecho romano, en cambio, toda relación en que interviene el Estado toma un carácter público que la distingue netamente de las existentes entre los particulares para el logro de fines económicamente análogos; veremos cómo ocurre esto, al estudiar las personas jurídicas (cfr. p. 78).

Pero, en fin, es necesario recordar que ni siquiera este problema de la distinción entre derecho público y privado pareció a los romanos tan digno de estudio como a nosotros. Y la razón de ello no reside únicamente en la ya señalada indiferencia de los romanos frente a la teoría pura, sino también y más aún en el hecho de que su atención se hallaba concentrada sobre el derecho privado del cual solamente emprendieron la sistematización. Tan cierto es ello que, como ya se ha dicho (p. 9, n. 5), aquella misma expresión *ius publicum*, que en el citado pasaje de ULPIANO y en algún otro fragmento puede traducirse aproximadamente como *derecho público* en el significado actual (*derecho pertinente al Estado*), designa en cambio, más a menudo, la norma *proveniente del Estado*, en antítesis con las reglas que las partes fijan a la conducta propia o ajena en los negocios jurídicos: cuando se dice, por ejemplo, que "*ius publicum privatorum pactis mutare non potest*", se quiere decir que el acuerdo entre particulares, mientras puede señalar libremente, dentro de los límites puestos por su discrecionalidad, los términos de cada obligación y facultad, no puede en cambio derogar aquellos efectos que el ordenamiento jurídico vincula indisolublemente a ciertos tipos de negocio, o —más generalmente— a ciertos hechos jurídicos. La ciencia moderna distingue este estado de cosas hablando de derecho *imperativo* en antítesis de derecho *dispositivo*: nosotros llamaremos *dispositiva*, por ejemplo, a la norma del derecho romano clásico por la cual el comodatario responde de la custodia en la conservación de la cosa prestada, en cuanto las partes de un contrato particular puedan establecer que cesa tal responsabilidad; pero en cambio



llamaremos imperativa, en este como en cualquier otro contrato, a la norma de la responsabilidad por dolo, de la que no se admite derogación.

Otra distinción de carácter sistemático es la que se establece entre *ius commune* y *ius singulare*<sup>17</sup>. "*Ius singulare est*", según la definición de PAULO en D. 1, 3, 16, "*quod contra tenorem rationis propter aliquam utilitatem auctoritate constituentium introductum est*". La definición nos presenta al derecho singular como una disposición divergente del sistema de un ordenamiento jurídico determinado, no correspondiente, en consecuencia, a la *ratio iuris*, aunque sugerida por motivos de utilidad práctica. Pero también aquí es preciso cuidarse de la tentación de interpretar literalmente: consideraciones de utilidad existen no sólo en la base de las normas de derecho singular, sino en la de todas las normas jurídicas; y si las normas no singulares se inspiran en una *ratio*, es decir, en un criterio de equilibrio entre los diversos intereses en juego y entre las diversas partes del sistema jurídico, la norma del derecho singular no niega esta *ratio*, pero reconoce que en algunas hipótesis, partícipes a primera vista de los mismos caracteres, impera en cambio una *ratio* distinta. Sin embargo, es cierto que mientras en la norma común los elementos de equilibrio que la encuadran perfectamente en el sistema saltan a la vista del observador, en la norma de derecho singular la atención es atraída inmediatamente por las razones de utilidad práctica que han aconsejado derogar los principios; y esto basta para explicar las palabras de PAULO.

En contraposición con el derecho singular, las normas de vigor general se agrupan, tanto entre los romanos como entre nosotros, bajo la denominación de *ius commune*.

Todo lo que hemos dicho significa que no deben ser confundidas con el derecho singular aquellas normas que, por la naturaleza de los intereses que protegen, atribuyen derechos e imponen deberes solamente a un número limitado de personas, o a una sola persona: tales las normas que fijan la competencia de las distintas magistraturas y de los órganos del Estado en general, o los deberes de los militares, o la posición de los hijos de familia. Pero frente a la norma por la cual toda persona, supuesta autora de delito,

<sup>17</sup> Sobre el tema, cfr. ORESTANO, *Ius singulare e privilegium in dir. rom.*, en los "Annali Univ. Macerata", XI, 1937, ps. 5 y ss.

puede ser sometida a proceso penal, es de *ius singulare* la que excluye al magistrado romano durante el año del cargo; y frente a las disposiciones relativas a los requisitos formales y sustanciales del testamento, es de *ius singulare* la dispensa, en favor de los militares, de la observancia de los mismos requisitos.

Estrecha conexión con el concepto de *ius singulare* guarda el de *privilegium*. El significado originario de esta palabra, que equivale a *lex in privos lata*, era el de norma emanada a danno de personas determinadas, sobre todo en el sentido de aplicar contra cualquiera una pena no prevista por leyes anteriores o de llamar a un tribunal para juzgar hechos cometidos en tiempo en que no constituían delito: privilegios semejantes (que la doctrina moderna llama *odiosi*) estaban prohibidos por una disposición de las XII Tabas (*privilegia ne inroganto*), aunque, sin embargo, varias leyes posteriores revistieron precisamente aquel carácter; sirva para todos el conocido ejemplo de la *lex Clodia de exilio Ciceronis* (año 58 a. C.), que aplicó contra el gran orador la pena del *aquae et ignis interdictio*, por el comportamiento que había asumido cinco años antes, en la represión de la conjuración de Catilina.

En cambio, en el lenguaje de los juristas clásicos la palabra ha adquirido, no sabemos a través de qué conductos, el significado, correspondiente al moderno, de norma constituida en beneficio de determinadas clases o grupos de personas: así se habla de *privilegium* a propósito del *testamentum militis*, o del *ius domum revocandi*, en virtud del cual ciertos magistrados, si son llamados a juicio en provincia, pueden pretender que la causa sea llevada ante el tribunal del pretor romano. En esta nueva acepción, el privilegio es una subespecie del derecho singular. Un tanto diversa es la acepción de la palabra cuando se usa para indicar los llamados *privilegia exigendi*, por los cuales ciertos acreedores están autorizados para cobrar sus créditos antes que cualesquiera otros sobre el patrimonio o sobre determinados bienes del deudor, sustrayéndose así al concurso de los coacreedores; es discutible, en efecto, según los criterios expuestos, si pueden reconocerse aquí los caracteres del *ius singulare*.

Pero, en cambio, hay que cuidarse de atribuir un significado técnico y unívoco a la expresión *beneficium*. Ésta se usa frecuentemente, como la correspondiente griega *φιλανθρωπία*, para indicar actos de la autoridad pública, especialmente del emperador, que impliquen ventajas para una o más personas o provincias o aun

para todos los súbditos; pero la palabra se emplea indiferentemente para actos de naturaleza normativa o para simples actos administrativos, y da lugar necesariamente, en el beneficio, a una excepción a la norma de alcance más general. En la época justinianeas se tiende a reservar este nombre a ventajas que se hallan indistintamente al alcance de todos los que se encuentran en cierta situación jurídica (lo que basta para excluir toda coincidencia con el *ius singulare*), pero que sólo se obtienen mediante solicitud expresa; así se llama *beneficium inventarii* a la facultad que tiene todo heredero, siempre que la reclame, de responder por las deudas hereditarias sólo dentro de los límites del activo de la herencia; y se llama *beneficium separationis* a la facultad que pueden obtener los acreedores del difunto para hacerse pagar sobre el patrimonio hereditario antes que éste se confunda con el patrimonio del heredero. Sin embargo, muchas otras veces (como en el caso de los tres *beneficia: divisionis, excusionis y cedendarum actionum*, correspondientes al garante, o en el del *beneficium competentiae*, en virtud del cual ciertos deudores sólo responden en los límites de sus facultades) se trata simplemente de expresiones acuñadas por los comentaristas medievales.

#### § 4. CLASIFICACIÓN DE LOS DERECHOS SUBJETIVOS. ADQUISICIÓN DE LOS DERECHOS Y SUCESIÓN.

Al lado de las distinciones del derecho objetivo corresponde recordar brevemente las de los derechos subjetivos, propias todas de la ciencia moderna. La menos lejana del pensamiento jurídico de los antiguos, aunque nunca haya sido formulada por ellos, es la distinción entre los derechos *absolutos* y los *relativos*. Como ya se ha señalado (p. 21), llámanse derechos absolutos aquellos a los cuales corresponden deberes negativos que gravitan sobre todos los coasociados, de modo que todos pueden tener ocasión de violarlos y ser alcanzados por los medios judiciales establecidos en defensa del titular; en cambio, se llaman relativos aquellos a los cuales corresponde un deber (a veces negativo, pero más a menudo positivo) de una o más personas determinadas. Es absoluto el derecho de propiedad, y relativo el de crédito; absoluto el derecho de la mujer a llevar el nombre del marido, y relativo el

derecho a la fidelidad conyugal. En el mundo romano, tal distinción halla su correspondencia en la distinción entre las acciones *in rem* e *in personam*, procedentes las primeras contra quienquiera que se interponga entre el titular y el bien sobre el cual se le permita mayor o menor libertad de acción; y las segundas contra quien está obligado, por contrato o por delito, a observar respecto de la contraparte cierto comportamiento (cumplimiento contractual o pago de la pena pecuniaria). Pero esta distinción entre las acciones es (como se ve a través de los ejemplos citados, y como se verá mejor en el cap. IV) mucho menos comprensiva que la que hoy se pone en la base de la estructura de los derechos subjetivos, y sin contar con que muchas veces, encarada desde el punto de vista de la acción, la relación jurídica es tomada en un momento poco adecuado para fijar su íntima estructura.

La distinción entre derechos absolutos y relativos es, por lo demás, como la distinción entre derecho público y privado y tantas otras que veremos en el curso de nuestros estudios, mucho menos neta y categórica de lo que parecería a través de la explicación que hemos dado. A menudo ocurre, en efecto, que una relación entre determinadas personas repercute sobre todo el consorcio social, exigiendo su respeto, y a veces este deber general subsiste también cuando ha cesado la primitiva relación individual; así, el derecho de crédito que corresponde a Ticio contra Cayo, no debe ser turbado por los terceros que impidan, por ejemplo, al segundo pagar; así, el derecho de servidumbre predial, que corresponde a todos los sucesivos propietarios de un fundo dominante contra todos los sucesivos propietarios de un fundo sirviente, se proyecta hacia el exterior en la obligación general de no oponer impedimento al ejercicio de la servidumbre y de no destruir las obras ejecutadas para el mismo ejercicio; así, el derecho de ser reconocido como hijo legítimo por los propios padres, da lugar al deber de todos los coasociados de considerar legítimo a quien, nacido en las condiciones previstas por la ley, no haya sido negado por quien tenía facultad para hacerlo. En las referidas situaciones, se tienen normalmente varios derechos subjetivos, relativos unos, absolutos los otros; pero no siempre puede establecerse netamente la separación, y a veces (como en el segundo y tercer ejemplo mencionados) la doctrina jurídica se halla frente a graves dificultades.

Más compatible con la mentalidad práctica de los juristas romanos es la distinción entre derechos *divisibles* e *indivisibles*, según pueda o no concebirse un goce parcial de los derechos (o en el sentido de una división material de la cosa corporal en que se funda el derecho, o en el sentido de un goce fraccionario del bien materialmente indiviso). Divisible es siempre, por lo menos en el segundo sentido, el derecho de propiedad (porque, aun cuando no sea divisible la cosa, los copropietarios pueden dividirse su goce o su rédito); los derechos de crédito son a veces divisibles y a veces indivisibles, y entran particularmente en la segunda categoría aquellos a los que corresponde la obligación del cumplimiento de una obra; las servidumbres son indivisibles porque existen para beneficio total del fundo dominante y no puede afirmarse, en consecuencia, que entre los diversos condóminos de éste cada uno las goce por su parte, pues las gozan en su totalidad o no las gozan.

No es romana la distinción entre derechos subjetivos *públicos* y *privados*, que establece la ciencia moderna según que la norma originaria del derecho subjetivo sea pública o privada (cfr. p. 32). Para los romanos es inconcebible esta distinción, porque el concepto que ellos tienen de las relaciones entre el individuo y el Estado, hace que la facultad de este último en el sentido de pretender un comportamiento dado de los particulares, se identifique sin residuos con el derecho en sentido objetivo, y que por otra parte, toda pretensión del particular frente al Estado, en tanto se refiera a la constitución y organización de éste, no sea concebible como relación entre dos sujetos contrapuestos, sino como problema interno del organismo estatal, donde el interés del individuo es completamente absorbido.

\*

\* \*

La ulterior distinción entre derechos *transmisibles* e *intransmisibles* nos lleva a considerar los conceptos generales referentes a la *adquisición* y *pérdida de los derechos*.

Si el derecho subjetivo es la facultad de pretender de alguien cierto comportamiento, y si la relación jurídica es el vínculo que se establece entre el titular de esa pretensión y la persona gravada

con la obligación jurídica correspondiente, tanto uno como la otra se individualizan por tres elementos: los dos sujetos, activo y pasivo, y el comportamiento (*objeto o contenido del derecho*). En rigor, debería deducirse que la relación jurídica desaparece cuando cambia uno cualquiera de los elementos referidos. Sin embargo, es insuperable la tendencia a objetivar ciertas relaciones, considerándolas impersonalmente en su estructura económica; y ello lleva a admitir su persistencia aun cuando uno de los sujetos sea sustituido por otra persona. Cuáles son las relaciones que pueden así objetivarse, depende en parte de razones técnicas diversas, pero sobre todo de la mayor o menor aptitud para la abstracción; también bajo este aspecto, como en tantos otros, el carácter concreto de la jurisprudencia clásica ha manifestado repugnancias que la doctrina bizantina, en parte, y mucho más la moderna, han sabido superar.

En sustancia, el derecho romano no reconoce traspaso de derechos de un titular a otro sino a título universal (*per universitatem*); sea en los casos, sin duda preeminentes, de la herencia y de esa análoga institución del derecho pretorio llamada *bonorum possessio*, sea en las hipótesis en que el titular de un patrimonio pasa bajo la potestad de otro, y convirtiéndose en persona *alieni iuris* pierde en beneficio del nuevo *pater familias* su patrimonio (*conventio in manum* de la mujer *sui iuris*: cfr. cap. XXI, § 1; *adrogatio*: cfr. cap. XXII, § 1), sea —finalmente— en la adquisición en bloque que un comprador hace de los bienes del ciudadano insolvente (*bonorum emptio*: cfr. cap. IV, § 2). En estos casos los romanos tienen la percepción nítida de un titular que toma el puesto de otro, que le *succedit*, y refuerzan el concepto hablando de *successio in locum et ius*: el heredero y los demás sucesores indicados ocupan el puesto del predecesor no sólo en la propiedad, sino en todos los derechos patrimoniales, reales o de crédito, que por su naturaleza no estén destinados a perecer con el primer titular. Fuera de estas hipótesis, y aparte alguna rara excepción de escasísima importancia (como el legado de un crédito), la transmisión de los derechos es ignorada por la jurisprudencia clásica. No se transmiten particularmente los créditos, ni las deudas, ni la prenda, ni la hipoteca; se transmite —diremos nosotros— la propiedad, pero no porque los antiguos la consideren como un derecho transmisible, sino por el cambio que se opera en su pensamiento entre la propiedad y la cosa sobre que recae. En conse-

cuencia, los juristas no podían elaborar un concepto de *successio* tan amplio como el que rige en la doctrina actual, para la cual sucede tanto quien ocupa en bloque la posición jurídica de un difunto, como quien toma el puesto del precedente titular en una relación jurídica cualquiera; por lo tanto, no podían distinguir una *sucesión a título universal* de otra *a título particular*. A esta concepción y distinción sólo ha podido llegar el derecho justiniano, después que una abstracción más refinada supo separar en la transmisión de las cosas la transmisión del derecho de propiedad, después que se hubieron afirmado los derechos transmisibles sobre las cosas de otros (enfiteusis y superficie), después que fuera netamente reconocida la cesibilidad de los créditos. Es en esta época cuando se habla por primera vez de *successio in res* o *in singulas res*, como contrapuesta a la *successio in universitatem* o *in universum ius*<sup>18</sup>.

Esto sentado, la distinción entre derechos y obligaciones transmisibles e intrasmisibles se plantea, para el derecho romano, exclusivamente desde el punto de vista de la sucesión que nosotros decimos a título universal, y de la sucesión hereditaria especialmente. Diremos, pues, que son transmisibles aquellos derechos y obligaciones que pasan inmutados al sucesor; intrasmisibles son aquellos que se extinguen con la persona del titular, aunque eventualmente nazca para otra persona un derecho u obligación de igual contenido. Transmisibles son, por ejemplo, la propiedad, la gran mayoría de los créditos, casi todas las deudas procedentes de contrato; intrasmisibles son el usufructo y las obligaciones derivadas de delito; lo es también la potestad, porque, si bien a la potestad del abuelo sobre los nietos la sustituye, a la muerte del jefe del grupo, la potestad del padre sobre los hijos, ésta no deriva de aquélla, sino que surge *ex novo* por el hecho de que el padre se ha convertido a su vez en el jefe del grupo.

Considerando los diversos modos de adquisición de los derechos, se distingue la *adquisición a título originario* de la *adquisi-*

<sup>18</sup> Sobre el desenvolvimiento terminológico, cf. LONGO, *L'origine della successione particolare nelle fonti di diritto romano*, en "Bull. Ist. Dir. Rom.", xiv, 1901, ps. 127 y ss., 224 y ss.; xv, 1903, ps. 283 y ss.; BONFANTE, *La successio in universum ius e l'universitas*, en los *Studii in onore di V. Scialoja*, I, ps. 533 y ss.; AMBROSINO, *Successio in ius*, etc., en "Stud. e Document.", 11, 1945, ps. 65 y ss., y sobre el traspaso de las cosas corporales de FRANCISCI, *Il trasferimento della proprietà*, Padova, 1924.



*ción a título derivado*, expresiones éstas que se emplean preferentemente en materia de propiedad. La adquisición es a título originario cuando coincide con el nacimiento de la relación jurídica objetivamente considerada (por ejemplo, la adquisición de la propiedad sobre una perla extraída del fondo del mar) o cuando se cumple sin relación alguna con el derecho que otros tenían sobre el mismo objeto (por ejemplo, la adquisición de la propiedad sobre una cosa abandonada); en cambio, es a título derivado cuando su causa es un acto de disposición (por ejemplo, tradición) del precedente titular. Una categoría especial que suele incluirse entre las dos mencionadas, es la *adquisición a título constitutivo*, característica de los derechos sobre las cosas ajenas, como el usufructo y las servidumbres prediales. También en ésta, como en la adquisición a título derivado, la causa es un acto jurídico donde interviene una persona que tiene el poder de invertir del derecho al nuevo titular; pero no se trata de la transmisión de un derecho ya existente, sino de la limitación del derecho del constituyente, producida habitualmente mediante la separación de facultades que formaban parte de él, y que pasan a constituir el contenido del nuevo derecho. Desde un punto de vista formal, la adquisición quedaría incluida entre las denominadas a título originario; pero la valoración económica, que hace ver en la propiedad así limitada y en el derecho sobre la cosa ajena nuevamente surgido las dos partes resultantes de una *división cualitativa* de la plena propiedad preexistente, aconseja la construcción de una categoría especial.

## § 5. LA INTERPRETACIÓN DEL DERECHO

Concepto romano de *interpretatio*: la posición de la antigua jurisprudencia frente a la ley y a la costumbre. Máximas interpretativas. Las limitaciones impuestas por Justiniano a la actividad de los intérpretes y las adaptaciones prácticas de las escuelas bizantinas. Los romanistas y la interpretación de las fuentes jurídicas romanas: la investigación del puro derecho justiniano; la investigación histórica a través del *Corpus iuris*; la *duplex interpretatio*. Interpretaciones e interpolaciones.

*Interpretari* es esencialmente, tanto para los romanos como para nosotros, el procedimiento mental de quien, en presencia de una norma jurídica, busca captar su pleno y exacto significado.

Nosotros consideramos este procedimiento confiado particularmente al juez, en el acto en que debe aplicar al caso sometido a su conocimiento la norma que le conviene, y sólo subsidiariamente como misión también del estudioso doctrinal; en cambio entre los romanos, las normas del ordenamiento judicial y del proceso hacen muy poco visible —y en el período más antiguo, absolutamente excepcional— semejante análisis por parte del juez, y la obra de interpretación constituye la esfera de acción, doctrinal y práctica al mismo tiempo, del jurista.

Pero no hay que creer, especialmente en las primeras fases del desarrollo del derecho romano, que los modos y la función de la *interpretatio* hayan sido los mismos que observamos y practicamos en el mundo moderno. Entre nosotros, la ley escrita tiende a traducir (aunque prácticamente no pueda lograrlo) todo el derecho vigente: esto sentado, el intérprete está obligado a entender ante todo la ley en su letra y en su espíritu, y si las leyes son diversas, a coordinarlas entre sí. En cambio, el intérprete romano fué esencialmente, durante toda la época republicana y aun después, intérprete de una costumbre que, mientras en sustancia era considerada eterna e inderogable, se la reconocía capaz de aplicaciones indefinidas siempre que ellas encuadraran en los esquemas prefijados de los negocios jurídicos y de las acciones judiciales. De este desarrollo, que no puede definirse correctamente sino como consuetudinario, los juristas son prácticamente promotores y verificadores: aunque desde el punto de vista constitucional ni los juristas contemporáneos y sucesivos ni el magistrado judicial están obligados a respetar, por ejemplo, el negocio últimamente adaptado por este o aquel perito para el logro de nuevos resultados, la práctica romana acepta esas adaptaciones del *ius civile* que consienten los técnicos más autorizados.

Por eso la antítesis entre *ius* y *lex*, a la que nos hemos referido varias veces (ps. 2 y 26), se traduce a menudo en la otra antítesis entre *lex* e *interpretatio*; palabra, esta última, que no debe referirse a la ley sino a la costumbre. Así POMPONIO, al hacer la historia del derecho romano (D. 1, 2, 2 § 12), podía distinguir entre esa parte del derecho que "*lege constituitur*" y aquella que "*in sola prudentium interpretatione consistit*". Del mismo modo se explica el nombre de *iuris conditores*, y hasta de *legum inventores*, que vemos atribuido a los juristas en textos jurídicos y no jurídicos.

En aquella parte de su actividad que más ajustada se mantuvo a textos legislativos o edictales o a otras fuentes autoritarias, los juristas tuvieron ocasión de adoptar los medios y alcanzar los resultados descritos por las doctrinas actuales de interpretación (interpretación *gramatical* y *lógica*, interpretación *extensiva* y *restrictiva*, analogía directa e indirecta, etc.); pero, conforme a sus tendencias mentales, no teorizaron los métodos que la oportunidad les sugería de tanto en tanto. Sólo nos han dejado algunos cánones que la práctica de la interpretación demostraba aplicables a vastos grupos de casos, y que todavía se citan y aplican en nuestros días siempre que se tenga en cuenta que su generalidad admite múltiples adaptaciones<sup>19</sup>.

La diversa concepción posclásica de las relaciones entre ley (en el nuevo sentido de constitución imperial) e intérprete, que al someter completamente éste a aquélla fué una de las principales causas de la decadencia jurídica y de su reducción a la oscura y modesta labor de las escuelas posclásicas (siglos iv a vi d. C.), encontró su expresión más soberbiamente burda en la constitución *Tanta* (§ 21), en la que JUSTINIANO, al ordenar la publicación del Digesto, sancionaba "ut nemo neque eorum, qui in praesenti iuris peritiam habent, nec qui postea fuerint, audeat commentarios isdem legibus adnectere", y conminaba contra el trasgresor las penas de la falsedad. Sin embargo, se hacían algunas excepciones al precepto, permitiendo traducciones literales (*κατὰ πόδα*) en griego, como también notas marginales con indicación de pasajes correlativos (*παράτιτλα*); y es evidente, aun queriendo observar

<sup>19</sup> Valgan, por ejemplo, los cánones siguientes:

"In ambigua voce legis, ea potius accipienda est significatio quae vitio caret" (D. 1, 3, 19): preferencia por aquella interpretación que hace a la norma más conforme al sistema a que pertenece.

"Incivile est, nisi tota lege perspecta, una aliqua particula eius proposita iudicare vel respondere" (l. 24, h. t.): toda ley (como todo sistema jurídico) debe estudiarse y tomarse en su conjunto, y la interpretación fundada sobre frases o disposiciones aisladas está sujeta a errores.

"Seire leges non hoc est verbum earum tenere, sed vim ac potestatem" (l. 17, h. t.): insuficiencia de la interpretación meramente gramatical.

"In re dubia benigniorem interpretationem sequi non minus iustius est quam tutius" (D. 28, 4, 3 = 50, 17, 192 § 1); o, con oportuna limitación, "in poenalibus causis benignius interpretandum est" (D. 50, 17, 155 § 2).

"Quod contra rationem iuris receptum est, non est producendum ad consequentias" (D. 1, 3, 14): exclusión de la analogía (no ya, como se suele afirmar, también de la interpretación extensiva) para las normas de derecho singular.

rígidamente los límites de tales excepciones, que la interpretación de los textos era supuesto de ellas. Por lo demás, ni aun los maestros bizantinos coetaneos de JUSTINIANO observaron con toda exactitud esos límites; antes bien, fueron reuniéndose muy pronto en torno a particulares pasajes de la compilación, desarrollos, ejemplificaciones y dilucidaciones, parte de las cuales nos ha sido conservada en los escolios de las Basílicas (cfr. p. 8).

\*  
\*   \*  
\*

El problema de la interpretación de las fuentes jurídicas romanas y del *Corpus iuris* especialmente, resurgió en el siglo XI con el renacimiento de los estudios romanísticos, y se ha mantenido siempre como problema fundamental, aun cuando en las diversas épocas se haya planteado en términos distintos; y al principio, en términos no disímiles de aquellos con que se plantea el problema de la interpretación de cualquier ley vigente, pero con las mayores dificultades que derivaban del hecho de tener que utilizar textos pertenecientes a diferentes épocas, y muchos siglos después de que aquellos miembros dispersos habían sido reunidos con fines legislativos. Los procedimientos de la jurisprudencia medieval, glosadores y posglosadores (siglos XI a XV), no fueron muy diferentes de los adoptados por los jurisconsultos romanos; a través de las diversas partes de la compilación bastaba escoger, para darles la máxima importancia, los rasgos que representaban el pensamiento, más moderno, del legislador bizantino; y basarse en ellos para nuevos desarrollos doctrinales y prácticos conformes a las necesidades de los tiempos nuevos. Por lo tanto, frente a las muchas e inconciliables contradicciones que presenta el *Corpus iuris* (en vano negadas por JUSTINIANO), y de cualquier época que fuesen las obras o las constituciones originales, se dió preferencia a los pasajes correspondientes a las ideas profesadas por JUSTINIANO en sus propias constituciones; y cuando se trataba de textos en contradicción, de los cuales uno era *in sede materiae* y el otro injertado en la consideración de materia distinta, se daba preferencia al primero. Otras veces, en presencia de contradicciones no superables, se crearon doctrinas sutiles destinadas a distinguir, según criterios de equidad o de utilidad objetiva, los gru-

pos de casos a los que pudiera aplicarse respectivamente una u otra máxima. Y en fin, cuando la interpretación que se daba de un texto según el espíritu justiniano no parecía conciliable con la época en que había sido escrito por primera vez, se recurría a la llamada *duplex interpretatio*, es decir, se daban dos interpretaciones diversas, una de las cuales debía referirse al primero o más antiguo legislador o escritor, y la otra a los compiladores justinianos. No de diversa manera estudiaban los textos los pandectistas alemanes y con ellos los italianos, en el siglo XIX, cuando el derecho romano era aún el derecho vigente en Alemania (*usus modernus pandectarum*); solamente que, junto a esta especie de interpretación, fué adquiriendo cada vez mayor significación (aunque completamente aparte) la investigación histórica.

Hoy, desaparecido de todas partes el derecho romano como ley actual, los textos del *Corpus iuris*, como los de todos los otros que nos han llegado, tienen para nosotros el único valor de documentos históricos; y nuestra misión es establecer, a través de su estudio, las reglas y el espíritu del derecho romano en las diferentes fases de su desarrollo. Por este mismo camino se introdujo, desde el siglo XVI, la escuela de los juristas cultos, que se honró con los nombres de ALCIATO y CUIACIO, pero las necesidades de la práctica impidieron el predominio de su orientación; en los últimos años del siglo pasado, tras los esfuerzos aislados de algunos estudiosos italianos (ALIBRANDI), las investigaciones histórico-romanísticas hallaron su verdadero camino tanto en Alemania como en Italia. Ello significa que los textos de la compilación son estudiados con diferente criterio, según se consideren como parte de la compilación misma o como escritos y constituciones clásicas. Mientras que para el primer fin sirven los mismos criterios interpretativos adoptados por los viejos romanistas, para el segundo se requieren criterios distintos, antes bien, opuestos: rechazamos, por ejemplo, como espúreos, esto es, no pertenecientes al jurista cuyo nombre llevan, los textos que parecerían remontar hasta la edad clásica innovaciones proclamadas en otras partes por JUSTINIANO como propias; y entre dos textos en discusión, uno *in sede materiae* y el otro fuera de *sede*, preferimos el segundo, porque entre los dos es probablemente mucho más manipulado por los compiladores el primero, que atraía más directamente su atención. En general, salvo en los casos en que se reconoce netamente una

divergencia entre los juristas, nos inclinamos a atribuir las contradicciones a las interpolaciones que los mismos compiladores efectuaron o hallaron ya realizadas por las escuelas, y a las imperfecciones del trabajo de retoque o adaptación ejecutado en el curso de muy pocos años (del 528 al 534). Métodos que presentan, desgraciadamente, infinitas posibilidades de error, y que en la mayor parte de los casos llevan solamente a la formulación de hipótesis más o menos provisionales; pero que son, sin embargo, los únicos que nos permiten trabajar, con la esperanza de cada vez mejores éxitos, en la reconstrucción exacta tanto del derecho clásico como del justiniano: desdeñarlos por su inexactitud es tan ingenuo como jurar sobre toda conquistada apariencia de verdad, y acaso es solamente la fe ciega que hoy profesan los más exaltados entre los neófitos, la que justifica en parte las repugnancias de los últimos misoneístas.

FRANJA  
MORADA

# FRANJA MORADA



## CAPÍTULO II

### LOS SUJETOS DEL DERECHO (PERSONAS FÍSICAS Y JURÍDICAS)

#### § 1. CONCEPTOS GENERALES Y TERMINOLOGÍA

La ciencia moderna llama *sujetos de derecho* a todos aquellos seres a quienes el ordenamiento jurídico considera como posibles titulares de derechos y de obligaciones, capacidad para la cual no se requiere, conceptualmente, la existencia actual de derechos y de obligaciones, sino que basta la aptitud del sujeto para adquirirlos; sin embargo, esta observación carece de valor práctico, ya que no es concebible —por cuanto anteriormente se ha dicho (cfr. p. 21)— un ser que viva en una sociedad, y sea reconocido como miembro de ella, sin ser sujeto, activo o pasivo, de innumerables relaciones.

La condición de los seres a quienes el ordenamiento jurídico considera sujetos de derecho, se llama *capacidad jurídica o de derecho*, o (en antítesis a la capacidad de obrar, de la cual hablaremos en breve) *capacidad de goce del derecho*.

La terminología hasta aquí empleada no es romana; como tampoco lo es, aunque haya sido elaborada por los romanistas sobre la base de alguna expresión más o menos equívoca de nuestras fuentes, la designación de los seres capaces de derecho con el nombre de *personas*, con la consiguiente distinción entre *personas físicas* (hombres a quienes el ordenamiento reconoce la capacidad) y *personas jurídicas* (seres distintos del hombre, pero dotados también de capacidad). Este significado de *persona* es desconocido para la jurisprudencia clásica: antes bien, la palabra es usada por ella solamente en el mismo sentido derivado<sup>1</sup> que en

<sup>1</sup> El sentido originario es notoriamente el de *máscara*.

la latinidad áurea y dominante, es decir, como equivalenté de hombre. Por eso, por ejemplo, GAYO, después de haber anunciado la exposición del *ius quod ad personas pertinet* (I, 8), continúa proponiendo como "*summa divisio de iure personarum*", a la que distingue entre *liberi* y *servi* (I, 9); y así sucesivamente, desarrollando aquella "*alia divisio de iure personarum*" que consiste en que sean *sui iuris* o *alieno iuri subiectae* (I, 48), comienza por señalar que "*in potestate sunt servi dominorum*" (I, 52). No se podría desear afirmación más explícita de la pertenencia de los siervos al número de las personas, aunque resulte para los juristas algo natural que el siervo sea objeto antes que sujeto de derechos. Por el contrario, la exposición gayana de *personis* no concede siquiera una mirada a las que nosotros llamamos personas jurídicas: donde, a propósito de otra materia, GAYO discurre, o donde otros juristas discurren de entes (*universitates, collegia, etc.*) que nosotros acostumbremos reunir bajo aquella denominación, la palabra *persona* no se encuentra nunca. Sólo en época avanzada algún escritor aislado, y no jurista, usa en sentido metafórico la palabra *persona* a propósito de corporaciones, y con referencia a los hombres, la imitación del lenguaje de los teólogos cuyas discusiones giran alrededor de las *personae* (πρόσωπα) de la Trinidad, lleva a dar a la palabra un colorido y una dignidad espiritual: por ejemplo, en la Paráfrasis de Teófilo a las Instituciones (3, 17 pr.), *ad verba* οἱ οἰκέται ἀπρόσωποι ὄντες ἐκ προσώπων τῶν οἰκείων δεσπότην χαρακτηρίζονται. Que en este pasaje y en otros semejantes πρόσωπον (o persona) sea deliberadamente usado para indicar al sujeto de derecho, es más que controvertible; pero es cierto que en ellos se encuentra la primera raíz de la doctrina de la personalidad, como se fué formando en las escuelas romanísticas del medievo<sup>2</sup>.

Los términos a través de los cuales la jurisprudencia romana intenta aclarar sus ideas sobre la posición del individuo (nunca

<sup>2</sup> Confróntese sobre el asunto, SCHLOSSMANN, *Persona und πρόσωπον im Recht und im christlichen Dogma* [...en el derecho y en el dogma cristiano], Kiel, 1906; PEROZZI, *Ist.*, 2ª ed., I, ps. 176 y ss. En cuanto a la palabra *capacitas*, la jurisprudencia la usa solamente con relación a la adquisición (*capio*) de herencias y legados, para indicar que no concurren las circunstancias que según las normas de la legislación matrimonial de Augusto excluyen, en todo o en parte, a determinadas categorías de personas.

de la llamada persona jurídica) con relación al ordenamiento jurídico, son los de *caput* y de *status*. Pero también aquí es necesario cuidarse de la tendencia a buscar en el lenguaje de los antiguos un sentido dado que se acomode a las ideas modernas. *Caput* significa, ante todo, *cabeza* y, en consecuencia, *individuo*, principalmente individuo humano; que puede ser indiferentemente un *servile caput*, como en D. 4, 5, 3 § 1, o un *liberum caput*, como en D. 26, 1, 1 pr. La ilusión moderna de un significado técnico deriva del comprobado tecnicismo de la expresión *capitis deminutio*, la que indica, en el lenguaje de los clásicos, la pérdida que un individuo sufre de la libertad, o de la ciudadanía, o de la posición que ocupaba en la familia. El uso originario de *capitis deminutio* debió ser con relación al grupo, que disminuía en un miembro: sea este grupo el *populus*, como cuando uno de los ciudadanos pierde la *civitas libertasque* (*capitis deminutiones maxima* y *media* de los juristas), o sea la familia, como cuando uno de sus miembros sale de ella por emancipación o entra a formar parte de otra por adopción o matrimonio *cum manu* (*capitis deminutio minima* de la terminología posterior)<sup>3</sup>. Más tarde, la expresión fué usada con relación al individuo, y se dijo sufrir una *capitis deminutio*, ser *capite deminutus* (o *minutus*)<sup>4</sup>: de donde vendría el hecho de traducir *caput* por "posición jurídica". Por otra parte, fuera de la conexión con *deminutio* y *deminuere*, esta acepción de la palabra no es corriente entre los clásicos. Sólo los bizantinos dieron un paso decisivo conforme a las tendencias más sutilmente especulativas de su pensamiento: la máxima *servile caput nullum ius habet*, dada por PAULO en D. 4, 5, 3 § 1, se vuelve en las Instituciones justinianeas (1, 16, § 4) *servus... nullum caput hab (e) t*; y es éste el único lugar de las fuentes latinas en que *caput* significa precisamente capacidad jurídica<sup>5</sup>.

Mucho más importante es, en la terminología romana, la palabra *status*, la que expresa cualquier posición o situación y, en

<sup>3</sup> Cfr. en este sentido, BESELER, *Contributi*, IV, p. 92. Hipótesis, cierto; pero que me parece preferible a la de AMBROSINO, "Stud. e Doc.", IV, 1940, ps. 369 y ss.

<sup>4</sup> Así también HORACIO (*Carm.*, 3, 5, 42), aludiendo a la posición de Atilio Regulo como prisionero de los cartagineses (y, en consecuencia, privado del *status libertatis*), la llama *capitis minor*.

<sup>5</sup> No por nada colaboraba en las *Instituciones* aquel mismo Teófilo, que, como se ha visto, llamaba *ἀνθρώποι* a los esclavos (cfr. p. 50).

consecuencia, con relación a la persona física, la situación del individuo frente al ordenamiento jurídico, como hombre libre (*status libertatis*) o como ciudadano (*status civitatis*) o como padre de familia (*status familiae*). La doctrina romanística no puede dejar de seguir el ejemplo de los viejos juristas, organizando en torno a los tres *status* las reglas fundamentales acerca de la capacidad jurídica<sup>6</sup>.

De ésta se distingue hoy netamente, como se ha señalado, la *capacidad de obrar*, es decir la aptitud, reconocida al individuo por el ordenamiento jurídico, de hacer declaraciones de voluntad (negocios jurídicos) con el efecto de modificar de cualquier modo las relaciones de derecho existentes. La capacidad de obrar puede faltar a individuos dotados de plena capacidad jurídica: así, el infante *sui iuris*, que es titular de su patrimonio, es incapaz para todo negocio jurídico. Pero hay que observar que el derecho romano exige, hasta donde sea posible, que la palabra creadora de los negocios jurídicos sea pronunciada por el individuo mismo que se beneficia o queda vinculado, aunque sea con la asistencia de una autoridad protectora (así, el pupilo salido de la infancia, obra él mismo con la *auctoritas tutoris*); y que, por otra parte, se puede tener plena capacidad de obrar aun siendo incapaz de derecho (así, el esclavo puede contratar, adquiriendo derechos para el patrón y, dentro de ciertos límites, obligándolo, y adquiriendo asimismo para sí créditos y deudas naturales).

## § 2. COMIENZO Y EXTINCIÓN DE LA PERSONA FÍSICA

Para que un hombre (sea o no sujeto de derecho) exista, es necesaria la completa separación de su cuerpo del cuerpo materno, que se llama *nacimiento*. Y es además necesario que el hombre nazca *vivo*; la prueba de la vida, que debe ser suministrada por quienquiera que tenga interés en ello, debía ser produ-

<sup>6</sup> Las ideas expuestas, aunque en alguna parte divergentes de las doctrinas recibidas, no coinciden con las sostenidas por COLI, *Saggi critici su le fonti del diritto romano*: I. *Capitis deminutio* (1922); en particular, mientras reconozco que la expresión *capitis deminutio* se refiere en la mayoría de los casos a la *minima*, no me parece alcanzada la demostración de que *capitis deminutio* y *status* contemplen siempre y solamente la posición del ciudadano en la familia.

cida, según la doctrina (aparentemente rigurosa) de los proculeyanos, demostrando que el recién nacido hubiese emitido un vagido; en cambio, los sabinianos, cuya doctrina prevaleció y fué acogida también en el derecho justiniano, consideraron que era suficiente cualquier signo, en particular el movimiento o la respiración. No se considera nacido vivo al aborto, ni siquiera si es ya capaz de respirar; solamente en este sentido se puede admitir que los romanos reconocieran el requisito de la llamada vitalidad<sup>7</sup>. Los romanos se detuvieron también sobre el problema de si puede ser reconocido como hombre el sér que, nacido de mujer, no tenga forma humana (criatura existente, en verdad, más en el mundo de los prejuicios que en el de la realidad); el problema fué resuelto de distintas formas, pero parece poder deducirse de las fuentes que corresponde la afirmativa cuando la norma considera a la procreación como título de mérito para los padres (especialmente para el *ius liberorum* correspondiente a la mujer que haya procreado cierto número de hijos), y que procede, en cambio, la negativa toda vez que se tratara de ver en el monstruo a un titular (aunque sea momentáneo) de derechos y de obligaciones.

La regla que requiere el nacimiento del hombre para que se tenga un sujeto de derecho, parecería violada por la afirmación de que "*qui in utero sunt, in toto paene iure civili intelleguntur in rerum natura esse*" (D. 1, 5, 26), afirmación que la tradición científica ha traducido en la máxima "*conceptus pro iam nato habetur*". Las dos expresiones son aproximativas: al feto todavía no nacido no corresponden jamás derechos y obligaciones, ni otros pueden pretender adquirir derechos por conducto de un sér que vivió solamente una vida intrauterina. Únicamente es verdadero, por una parte, que al concebido le quedan reservados, especialmente en materia de sucesión, derechos que se fijarán en él cuando nazca, y que a este fin se puede nombrar, también, un administrador especial llamado *curator ventris*; y, por otra parte, que muchas veces, para regular el *status* del individuo ya nacido, se toman en cuenta presupuestos que existían al tiempo de la concepción y no al del nacimiento (así para establecer si el nacido

<sup>7</sup> Así, AMEROSINO, "Riv. It. Sc. Giur.", nueva serie, 15, 1942, pá. 3 y ss., que, en principio, me convence.

es ciudadano o peregrino, libre o esclavo, con relación al correspondiente *status* del padre)<sup>8</sup>.

En cuanto a la muerte del hombre, corresponde observar que la prueba incumbe a quien tenga interés en acreditarla. En la hipótesis de que varias personas, emparentadas entre ellas, de modo que una pudiese adquirir derechos y obligaciones como consecuencia de la muerte de la otra, muriesen en el mismo siniestro, sin que se pueda establecer cuál falleció primero, el derecho clásico las considera muertas en el mismo instante; el derecho justinianeo, en cambio, regulando el caso especial en que las personas en cuestión sean padre e hijo, considera premuerto al hijo si impúber, prefallecido al padre si el hijo era púber.

El derecho romano no conoce actas del estado civil: las declaraciones de nacimiento presentadas a la autoridad pública, de las cuales tenemos ahora ejemplos abundantes para Egipto, tienen para los provinciales el fin de asegurar, para el tiempo en que se cumpla la edad prescrita, la sujeción del individuo al impuesto llamado *capitatio*, o la pertenencia a diversas agrupaciones, y para los romanos residentes, la de evitar la indebida asunción de la ciudadanía por parte de quienes no tengan derecho a ella<sup>9</sup>.

<sup>8</sup> Sobre el tema, cfr. ALBERTARIO, *Conceptus pro iam nato habetur*, en "Bull. Ist. Dir. Rom.", XXXIII, 1923, ps. 1 y ss. (= *Studi di dir. rom.*, I, Milano, 1933, ps. 1 y ss.). El derecho clásico tiene en cuenta la concepción cuando se trata de establecer el *status* de un hijo nacido de justas nupcias o la posición hereditaria del hijo respecto del padre; en cambio, tiene en cuenta el nacimiento, cuando se trata de establecer el *status* de un hijo nacido fuera de justas nupcias, *status* que se determina con relación al de la madre. Y es natural que así sea: porque la paternidad está toda en la concepción, la maternidad está en el parto. Convengo con ALBERTARIO también en atribuir al derecho posclásico la regla por la cual para determinar el *status* del sujeto nacido fuera de matrimonio se tenga en cuenta ora el tiempo de la concepción ora el del nacimiento, según el que resulte más ventajoso al recién nacido. No veo, sin embargo, en qué sentido él atribuye a los justinianos la afirmación, repetida muchas veces en las fuentes, de que ninguno puede sacar ventaja de una gestación no llegada a término: puede ser que algún texto haya podido ser interpolado o glosado en este sentido, pero solamente porque los clásicos rehuían expresar un "truismo" semejante, no ya porque vieran en él concebido un posible conducto para la adquisición de derechos. Para una más amplia discusión, cfr. ahora "Arch. Giur.", 4ª serie, 23, 1934, ps. 83 y ss.

<sup>9</sup> Ver declaraciones y certificados en mis *Negotia*, n.º. 1 a 3.

## § 3. EL "STATUS LIBERTATIS": LIBRES Y ESCLAVOS

El nacimiento de un hombre, que por derecho moderno es suficiente para que se le tenga como sujeto de derecho, no basta al mismo efecto para el derecho romano, dominado como está por la distinción entre libres y esclavos.

Común a todos los pueblos antiguos, y por eso definida como una institución del *ius gentium* (en el sentido más amplio), la esclavitud no tuvo, sin embargo, gran relieve en los orígenes de Roma: no sólo los esclavos faltaban en la familia plebeya, cuyos miembros libres (mujer, hijos y nueras) bastaban para ayudar al *pater familias* en el cultivo del fundo, sino que también el antiquísimo patriciado había recurrido con preferencia a los servicios de *clientes*, es decir, de plebeyos que se hacían conceder por las grandes familias la posesión precaria de tierras. Sólo como consecuencia de las guerras victoriosas, la cautividad de guerra, que fué siempre la fuente principal de la esclavitud, introdujo en la familia romana este elemento nuevo con tanta frecuencia como para sentirse la necesidad de dar a los hijos de familia, para distinguirlos, el nombre de *liberti*. Pero la mayor difusión de la esclavitud se tuvo en los últimos siglos de la República, y en los primeros del Imperio: las grandes masas de prisioneros que procedían de las guerras trasmarinas, más la concurrencia de los comerciantes romanos a los grandes mercados esclavistas de Grecia y de Asia Menor, y en fin —consecuencia de uno y otro fenómeno— el lujo desenfrenado de las clases pudientes, hicieron que los esclavos adquirieran en la metrópoli el predominio numérico, y que el trabajo servil llegase a eliminar al trabajo libre. Para impedir que el predominio numérico se trasformara, a través de las frecuentes concesiones de libertad (*manumisiones*), en predominio político de esta masa cosmopolita y advenediza sobre los ciudadanos romanos, fueron necesarias, bajo Augusto, las leyes restrictivas de las manumisiones. Sin embargo, el fenómeno de la esclavitud parece, para quien lo contemple a través de las descripciones que se refieren a la capital, más importante de lo que en realidad fué: la economía servil, que domina en Roma, tiene en las otras partes de Italia un predominio menos incontrastado, y fuera de Italia se encuentra sólo en las ciudades más ricas, mien-



tras en los vastos territorios de las provincias la esclavitud es excepcional. Y en la última época de la historia de Roma, cuando las grandes guerras de conquista hubieron cesado, y con ellas las grandes capturas de prisioneros; cuando las antiguas ciudades fueron perdiendo su lustre y todo el mundo romano se niveló a la medida de las provincias, también la esclavitud se hizo más rara, suplantada por el colonato y por la transmisión hereditaria de los oficios: no poco influyó en la misma dirección la enseñanza cristiana que, predicando la igualdad entre los hombres, favoreció nuevamente las manumisiones. En la compilación de JUSTINIANO la esclavitud figura siempre como institución vigente; pero, mientras en el Digesto se le dedican amplísimos desarrollos, en el Código, las constituciones de los últimos siglos muestran, con las pocas referencias que sobre ella contienen, cómo la institución está en el ocaso<sup>10</sup>.

Desde el punto de vista del derecho, el esclavo es considerado principalmente como objeto de dominio y de contrataciones entre los libres; y lo encontramos, con el nombre de *homo*, en las ejemplificaciones de las distintas categorías de cosas. Lo que no impide que sus características de criatura sensible e inteligente le reserven, entre las cosas, una posición particular: el esclavo puede realizar válidamente actos de adquisición del dominio o de derechos reales, con el efecto de adquirirlos para el patrón; puede ser instituido heredero por un extraño, con el efecto de que el patrimonio hereditario vaya, por su intermedio, al patrón; puede obtener del patrón mismo la asignación de un pequeño patrimonio (*peculium*), que sólo de hecho es suyo, pero que da lugar a la obligación del patrón de responder, dentro de los límites de la asignación, por las deudas que el esclavo contraiga ante terceros; transforma en *locus religiosus*, y, como tal, inalienable, la porción de terreno en que es sepultado. Si estas reglas, y otras análogas, no son técnicamente inconciliables con la subsunción bajo el concepto de cosa, constituye, en cambio, una verdadera y propia derogación el que sea el esclavo considerado como destinatario de normas penales, es decir, capaz de cometer delitos públicos, y,

<sup>10</sup> Sobre la evolución de la esclavitud, cfr. para todos ED. MEYER, *Kleine Schriften (Escritos menores)*, ps. 157 y ss.; CICCOTTI, *Il tramonto della schiavitù*, Torino, 1899; SOLAZZI, *Il lavoro libero nel mondo romano*, en el "Annuar. Univ. Macerata", 1905-1906; ROSTOVZEV, *Storia economica e sociale dell'imp. romano* (trad. Sanna, Firenze, 1933), ps. 141 y ss. y *passim*.

como tal, sujeto a pena pública: ya las XII Tablas fijan, por ejemplo, la pena de la *praecipitatio e saxo* (desde la roca Tarpeya) para el esclavo culpable de hurto flagrante, y, en la época imperial, CALISTRATO (D. 48, 2, 12, § 4) podía enunciar el principio de que "*omnibus legibus servi rei fiunt*". Más grave derogación es, en la edad imperial, el consentir al esclavo presentarse por vía extraordinaria ante el magistrado contra el patrón que oponga, en determinadas hipótesis, injustos obstáculos a su manumisión: como si hubiera sido sustraído por el heredero el testamento en el cual el antiguo patrón le concedía la libertad; o si el siervo, declarado libre en el testamento, a condición de que rinda cuentas de una administración, no llega a conseguir que el heredero acepte la rendición de cuentas; o, en fin (pero quizá solamente por derecho justinianeo), si habiendo comprado mediante su peculio la propia libertad, el amo no lo manumitiese.

A la idea de esclavo no es indispensable la de un amo actual; antes bien, tratándose de una *condicio personae*, la esclavitud subsiste desde el momento en que se verificó la causa que la provoca (sea el nacimiento de madre esclava u otra causa sobreviniente) hasta la muerte o hasta que una declaración de voluntad del patrón (*manumissio*) u otro presupuesto reconocido por el ordenamiento jurídico, determina su cesación. El hecho jurídico por el cual el siervo deja de pertenecer a un patrón sin pasar al dominio de otro (en especial la *derelictio*) hace de él un *servus sine domino*, ocupable como cualquier otra *res nullius*.

Aunque la esclavitud sea definida como institución del *ius gentium*, falta, sin embargo, respecto a ella, una verdadera comunidad de derecho entre romanos y extranjeros; así, no es considerada *iusta servitus* la del ciudadano romano que sirve en el extranjero como prisionero de guerra. Sin embargo, la observancia de las que se consideraban buenas normas de guerra en el mundo antiguo, hace que su condición no sea entendida como de mero hecho; antes bien, si ningún acontecimiento la elimina, el prisionero muere esclavo. Pero si llega a volver a entrar de cualquier manera en las fronteras del Estado, se verifica el *ius postliminii*, que importa no sólo la readquisición del *status libertatis*, sino también que éste se considere como si jamás se hubiera perdido; en consecuencia, todos los derechos y obligaciones que se concentraban en el ciudadano, y que la prisión de guerra había extinguido, renacen sin cambio alguno. Sólo aquellas situaciones

que aun teniendo relieve jurídico son esencialmente de mero hecho, como la posesión y (en el concepto romano) el matrimonio, no renacen: una nueva toma de posesión de las cosas, un resurgimiento de la *affectio maritalis*, respecto a la que había sido mujer, serían el punto de partida de una nueva posesión, de un nuevo matrimonio. La regla por la cual, al morir el prisionero de guerra sin que el *postliminio* se haya verificado, muere esclavo, daba lugar a consecuencias perjudiciales en materia de sucesión testamentaria; en efecto, la pérdida de la libertad (*capitis deminutio maxima*), quitando al ciudadano la *testamenti factio activa*, no sólo lo hacía incapaz de testar sino que anulaba el testamento anteriormente otorgado. Una ley Cornelia, aprobada por los comicios a propuesta de L. Cornelio Silla, alrededor del 81 a. C., puso remedio a este estado de cosas estableciendo que el prisionero muerto como tal se consideraba fallecido en el momento de la captura (*fictio legis Corneliae*)<sup>11</sup>.

El esclavo manumitido, que desde el punto de vista del *status libertatis* no se distingue de los otros libres, y que normalmente es partícipe —salvo las excepciones que veremos en el párrafo siguiente— también de los *status civitatis* y *familiae*, está, sin embargo, socialmente, y en parte también jurídicamente, en una posición especial, a la cual (lo mismo que a su contraria) los romanos dan también el nombre de *status*. Se distinguen, desde este punto de vista, *ingenuos* y *libertinos*: *ingenuos* son los que han nacido libres y permanecido siempre como tales; *libertinos* los que nacieron esclavos o de cualquier manera sufrieron una *iusta servitus*, de la que fueron liberados. La inferioridad de la posición de los *libertinos* actúa sobre todo en el campo del derecho público, en el sentido de exclusión de determinados cargos, de distribución en pocas tribus para hacer menos efectivo su voto político, etc.; pero también en instituciones del derecho privado se hace sentir a veces, como por ejemplo las leyes augusteas sobre el matrimonio, que conceden a las madres más prolíficas las ventajas comprendi-

<sup>11</sup> La estructura de las dos instituciones, especialmente para el derecho clásico, es discutida: cfr. RATTI, "Riv. It. Sc. Giur.", 1926, ps. 175 y ss.; "Bull. Ist. Dir. Rom.", 35, 1927, ps. 105 y ss., y en otros escritos; GUARNERI-CITATI, "Annali Univ. Messina", 1, 1927, ps. 19 y ss.; BESELER, "Rev. Fundac. Savigny", 45, 1925, ps. 192 y ss., y ahora SOLAZZI, *Scritti Ferrini*, 1, Milano, 1947, ps. 288 y ss. Para una grave y temporaria excepción al principio del *postliminium*, ver el estudio de E. LEVY cit. en p. 69, n. 20.

das bajo la denominación de *ius liberorum*, fijan el número mínimo de hijos en tres para las mujeres ingenuas y en cuatro para las libertinas, o como cuando se prohíben a los senadores las nupcias con estas últimas. Veremos posteriormente, en el estudio del derecho de familia y de sucesión (cap. XXIII, § 3, y XXV, §§ 3 y 4) que el libertino permanece en cierto modo ligado al antiguo patrón, ante el cual (*patronus*) toma el nombre de *libertus*.

#### § 4. EL "STATUS CIVITATIS"

Además de la libertad, la ciudadanía es, originariamente, condición para ser sujeto de derecho; el principio sufre, como veremos, muchas atenuaciones, y es diversamente aplicado; pero formalmente puede considerársele vigente en todas las épocas del derecho romano.

Como es sabido, el Estado de los pueblos clásicos se identifica con la ciudad y con su comarca; es más, entre los mismos habitantes de muchas ciudades subsiste, máxime en la edad más antigua, una distinción según la cual sólo los pertenecientes a la clase, orden o raza dominante son ciudadanos de pleno derecho, o al menos están muy reducidos los derechos políticos de los demás; así, en la primitiva Roma estaban muy reducidos los derechos políticos de los plebeyos. La supremacía de Roma en Italia se llevó a cabo al principio, sólo raramente mediante anexiones y más a menudo mediante alianzas (*foedera*) que dejaban a los habitantes en la condición de extranjeros. Ciudadanos de pleno derecho eran, bajo la República, además de los habitantes de la ciudad, los de las treinta y una tribus rústicas, cuyo territorio, aunque mucho más condensado en las regiones próximas, se extendía por todas partes de la Italia peninsular; pero, de cualquier manera, no superaba en su conjunto los veinticuatro mil kilómetros cuadrados<sup>12</sup>. La aspiración de los aliados itálicos a ser recibidos entre los ciudadanos, recogida desde la época de los Gracos en el programa de la democracia romana, sólo pudo ser llevada a la práctica como consecuencia de la guerra social (*lex Plautia Papiria*, 89 a. C.); a la Italia Septentrional, no comprendida en la verdadera Italia, sino

<sup>12</sup> Me valgo de los cálculos de BLOCH, *Römische Geschichte* [Historia romana], Berlín, 1926, ps. 620 y ss.

denominada Galia Cisalpina, y a Sicilia la ciudadanía les fué concedida sólo bajo la dictadura de César o inmediatamente después de su muerte.

Pero aun este movimiento, que trasformaba a Italia en la más enorme *civitas* que la antigüedad hubiera jamás visto, estaba bien lejos de agrupar en un solo organismo político a la población de todo el territorio sujeto al nombre romano; las provincias ocupadas mediante las conquistas trasmarinas o trasalpinas quedaban siempre habitadas por extranjeros (*peregrini*). Eran distinguidos en dos categorías, según que perteneciesen a una comunidad ciudadana preexistente a la conquista romana y que Roma hubiese dejado subsistir (*peregrini alicuius civitatis*), o no estuviesen organizados en ciudad, ya porque ninguna ciudad hubiese tenido nunca asiento en ese territorio, ya porque la ciudad preexistente había sido disuelta para castigarla por su resistencia (*peregrini dediticii*): los primeros eran aliados de Roma, o por lo menos formalmente independientes; los segundos, súbditos. Ante el derecho romano privado, la posición de unos y de otros era igual, siendo reconocido en general sólo aquella comunidad jurídica con los ciudadanos que resulta de las relaciones del *ius gentium*; pero mientras los *peregrini alicuius civitatis* gozaban de un *ius civile* propio, éste era negado a los *dediticii* por no concebirse un *ius civile* donde falta la *civitas*<sup>12</sup>.

Aunque la consecuencia es más doctrinal que práctica: de hecho, las leyes y costumbres ya vigentes entre los varios pueblos continuaron siendo aplicadas en las relaciones entre individuos de la misma nacionalidad, y a falta de órganos legislativos que puedan modificarlas provee la costumbre. Verdaderos *apolidi*, en el sentido de no poder invocar para sí otras normas que las del *ius gentium*, son los *dediticii Aeliani*, es decir, aquellos libertinos que han sufrido durante la esclavitud penas infamantes, y que la ley *Aelia Sentia* (año 4 d. C.) considera *dediticiorum numero*: a éstos les falta, no sólo de derecho sino también de hecho, la posibilidad de contraer relaciones que puedan referirse al derecho de una

<sup>12</sup> Tal es, por lo menos, la teoría dominante, hoy por muchos combatida: cfr. sobre el tema, además de los citados en la p. 63, nota 17: MOMIGLIANO, *Ricerche sull'organizzazione della Giudea sotto il dominio rom.*, en "Annali Sc. Norm. Sup. di Pisa", 3, 1934, ps. 89 y ss.; y LUZZATTO, "Stud. et Docum.", 2, 1936, ps. 210 y ss.

comunidad política cualquiera. Los otros *dediticii*, que en las provincias helenas parecen tomar el nombre de *δμολογοί*, se distinguen de los *peregrini alicuius civitatis* principalmente en el derecho público; sobre todo por estar sujetos al impuesto de la *capitatio* y (por lo menos en ciertos territorios) por estar excluidos también de las concesiones individuales de la *civitas Romana*, si antes no han pertenecido, por lo menos temporalmente, a otra comunidad ciudadana.

En ciertas provincias que ya antes de la conquista romana habían sufrido cambios complejos, los estratos étnicos en que se dividía la población, eran bastante numerosos. Con respecto a Egipto, un documento de la primera época imperial, que para fijar los derechos del fisco sobre las herencias vacantes toma en cuenta las diversas situaciones personales<sup>14</sup>, nos da la expresión completa del fenómeno: al lado de los ciudadanos romanos (diversamente tratados según que fueran ingenuos o libertinos) están los pertenecientes a la comunidad griega de Alejandría (*Ἀλεξανδρεῖς*), luego los de las ciudades griegas dispersas en Egipto; en consecuencia, la masa de egipcios, y todavía otras categorías, por una u otra razón inferiores.

Una posición intermedia entre ciudadanos y peregrinos es ocupada por los *latini*, a los cuales las fuentes distinguen en tres clases: *prisci*, *coloniarii*, *iuniani*. *Prisci latini* son, ante todo, los antiguos habitantes del Lacio. No es éste el lugar para detenerse a examinar la cuestión de si Roma ha sido fundada por los latinos (según lo quiere la tradición), o por los etruscos, que habrían sometido a una población latina preexistente (como muchos factores harían considerar), o si deriva de la fusión de varias comunidades de diverso origen<sup>15</sup>; lo cierto es que, por lo menos desde que la plebe obtuvo relieve político, las relaciones entre la ciudad y la restante población latina se hicieron cada vez más intensas. Quizá Roma misma formó parte, en algún período, del *foedus latinum*, en paridad de condiciones con las otras ciudades; pero, ciertamente, en época histórica, fueron concluidos nuevos *foedera* entre Roma, por una parte, y toda la confederación latina, por otra. Y fueron,

<sup>14</sup> Es el llamado *γνώμων* del ἰδιος λόγος; cfr. *Storia*, 5ª ed., ps. 245 y 285.

<sup>15</sup> Mis opiniones sobre la materia las he expuesto en la citada *Storia*, espec. en las ps. 15 y ss., y 43 y ss.

entre los *foedera* de los romanos con las diversas ciudades itálicas, los más favorables; mientras las ciudades latinas conservaron su constitución política y, en consecuencia, la propia legislación y jurisdicción, se admitió bastante pronto que los latinos presentes en Roma en los días de votación comicial pudieran participar en ella, siendo agregados, para la ocasión, a una entre las diversas tribus sorteadas, y se facilitó de todas maneras la adquisición individual de la ciudadanía, concediéndola, entre otros casos, a todo latino que hubiera desempeñado una magistratura en su ciudad natal. En el terreno del derecho privado se reconoció a los latinos el llamado *ius commercii*, o *commercium*, es decir, la capacidad de concluir con los romanos negocios solemnes *per aes et libram*, y se admitió además que fuesen recíprocamente tutores y pupilos. Una general admisión del *connubium*, es decir, de la recíproca capacidad matrimonial no se menciona en las fuentes jurídicas, pero de las fuentes literarias resulta que, por lo menos, las concesiones parciales han sido tantas como para convertir en excepcional la falta del *connubium*.

Se llaman *latini coloniarii* a los pertenecientes a las colonias latinas, es decir, a las colonias en las que fueron admitidos, además de los *cives Romani*, también los latinos, con el resultado de que en tales se trasformaban también los descendientes de los participes romanos. La latinidad colonial fue, pues, conferida, a partir de la dictadura de César, y más en la edad imperial, a regiones íntegras (por ejemplo, por Nerón al distrito de los Alpes marítimos; por Vespasiano a España): sólo que en estas ocasiones se van derogando uno tras otro los privilegios que los latinos colonarios tenían originariamente en común con los *prisci latini*.

Se llaman, en fin, *latini iuniani* los libertinos que, habiendo sido manumitidos en forma no solemne, son considerados por la *lex Iunia Norbana* (año 19 d. C.?) como libres, pero privados del *status civitatis*; la misma condición se imponía a los esclavos que hubiesen sido manumitidos antes de los treinta años de edad, en contravención a la prohibición de la ley *Aelia Sentia*. La posición de los junianos es muy inferior a la de los otros latinos, y fue elegantemente expresada con las palabras: *vivunt quasi ingenui, moriuntur ut servi*<sup>18</sup>; tienen, en efecto, el *commercium* con los romanos, pero están privados de la capacidad de testar, y a su

<sup>18</sup> SALVIANO, *Adv. avar.*, 3, 7 (en Migne, *Patr. lat.*, 53, 212).



muerte los bienes vuelven al antiguo patrón *iure peculii*, como si la manumisión no hubiese tenido lugar (con la consecuencia de que estos libertos pueden ser objeto, como los esclavos, de legados y fideicomisos).

\*  
\*   \*

La organización descrita, que deriva —como se ha visto— de la premisa del Estado-ciudad, estaba destinada a morir con éste; y, en efecto, una de las etapas hacia la transformación del Estado-ciudad en monarquía mundial fué la concesión de la ciudadanía romana a todos los habitantes del Imperio. En un pasaje de ULPIANO (D. 1, 15, 15), la innovación es presentada como introducida por un solo acto legislativo, es decir, por una constitución dictada por Antonino Caracalla, en el año 212 d. C. ("in orbe romano qui sunt, ex constitutione imperatoris Antonini cives romani effecti sunt"); la duda planteada hace tiempo, de que se excluyeran de la concesión de la ciudadanía algunas ínfimas categorías de la población, especialmente los *dediticii*, pareció a muchos confirmada por la versión griega de la constitución, llena de lagunas, encontrada en un papiro de Egipto; pero parece que, en cambio, no se opuso ninguna limitación de ese género<sup>17</sup>.

<sup>17</sup> El texto, que está publicado en el n° 40 de la colección de los papiros de Giessen (I, 1910), fué integrado por el editor (P. M. MEYER) así (las integraciones están entre corchetes): διδωμ...: ἅπασιν ξένους τοῖς κατὰ τὴν οἰκουμένην πολιτείαν Ῥωμαίων, [μ]ένοντος [παντός γε- νους πολιτευμ]άτων, χωρ[ις] τῶν [δεδ]ειτικίων; es decir, según la traducción que parece mejor *omnibus... peregrinis qui in orbe sunt civitatem Romanorum concedo, omni genere civitatum manente, praeter dediticios* (o *dediticias*). La opinión prevaleciente refirió primero las palabras finales al διδωμ (*concedo*), y consideró excluidos a los dediticios de la concesión; lo que llevaba a suponer que la palabras *exceptis dediticiis* se encontraran originariamente también en el pasaje de ULPIANO. Según una diversa interpretación, sostenida especialmente por SEGRÉ (*Studi in onore di S. Peruzzi*, ps. 147 y ss., cfr. *Scritti Giur.*, II, ps. 125 y ss.), las palabras χωρ[ις] τῶν δεδειτικίων limitarían, no la frase en que se concede la ciudadanía, sino aquella en que se declaran conservados todos los πολιτεύματα: subsistirán, en suma, las otras diferenciaciones políticas, pero habría que regular *ex novo* la posición de las comunidades dediticias. Tanto una como otra tesis dejan dudas: la primera porque la construcción gramatical resultaría forzada; la segunda, porque la palabra πολιτεύμα es usada en los papiros para indicar solamente ciertos grupos privilegiados (como el

De todas maneras, es cierto, por una parte, que las organizaciones ciudadanas, aparentemente conservadas por la constitución, no tuvieron más que cierta autonomía municipal, sucesivamente extendida, también, a los conglomerados urbanos que no habían sido nunca *civitates* en el sentido del antiguo derecho público, y también lo es, por la otra, que desde el primer momento los actos jurídicos privados, muchos de los cuales quedan en los papiros greco-egipcios, fueron realizados conforme al derecho romano, o por lo menos según la idea que de este derecho se hacían los provinciales. Lo que no quiere decir que con la *constitutio Antoniana*, o con las ulteriores extensiones que hicieron universal la concesión de la ciudadanía, haya desaparecido la distinción entre *cives* y *peregrini*, pues esta distinción subsiste también en la compilación justiniana; pero peregrinos son, en esta época avanzada, sólo los extranjeros al Imperio.

Una categoría que no podía sobrevivir a la *constitutio Antoniana* es, en cambio, la de los latinos: es natural, por lo tanto, que después del 212 no se tenga mención segura ni de los *latini prisci* ni de los *coloniarii*. Subsistieron los *latini iuniani*, cuya situación, aunque expresada en términos que se refieren al *status civitatis*, es, sustancialmente, de sujeción personal al antiguo patrón; antes bien, las causas de latinidad asimilada a la *iuniana* acrecieron con varios casos en los cuales el esclavo adquiría la libertad sin manumisión. Y por análogas razones subsistieron los de-

---

de los cretenses, el de la *guardia de corps* persa, el de los judíos de Alejandría) y para distinguirlos de la masa de los egipcios, de manera que no se puede pensar en estos últimos como en un *πολίτευμα*; también si se nos remite al *civitates* latino, se observa que difícilmente los romanos habrían dado a la palabra un sentido tan amplio como para comprender en ella a los pueblos no organizados en ciudad. Más recientemente se han intentado diversas integraciones e interpretaciones, y es ampliamente aceptada la propuesta por WILHELM ("Amer. Jo. of Arch.", 28, 1934, p. 180). [μ]ένοντος [οὐδενὸς ἐκτὸς τῶν πολιτευμάτων, χωρὶς, etc. Con esto el emperador observaría que en la aplicación del ordenamiento municipal, extendido por sus predecesores a todos los conglomerados urbanos de las provincias, cada uno —con excepción de los solos *dediticiis*— pertenecería a una *civitas*. Contra la idea de una doble ciudadanía, romana y local, con la consiguiente facultad de elección entre el derecho romano y el de las varias ciudades, idea muy difundida en los últimos tiempos, ver ARANGIO-RUIZ, *L'application du droit romain en Egypte après la constitution Antoninienne*, en el "Bulletin Inst. d'Égypte", 29, 1946-1947, ps. 83 y ss.

ditici de la ley Elia Sencia. Pero en las provincias orientales las dos instituciones tuvieron rara aplicación práctica, y, finalmente, fueron abolidas por constituciones de JUSTINIANO (C. 7, 6, 1; 6, 15, 2).

### § 5. EL "STATUS FAMILIAE"

En fin, la plena capacidad jurídica patrimonial está condicionada por el hecho de que el sujeto sea, por lo menos potencialmente, jefe de familia, no sometido a la potestad de otro. A este respecto corresponde señalar, anticipándonos a lo que se dirá al tratarse del derecho de familia, que los partícipes de la *civitas libertasque* se distinguen en personas *sui iuris* y *alienae potestati subiectae*. *Sui iuris* es el (o los) que no tiene ascendientes legítimos, o que ha sido liberado (*émancipatus*) por el ascendiente de quien dependía: se les llama también *patres familiarum*, independientemente del hecho de que tengan o no hijos u otras personas sometidas, como también sin consideración a la edad, que puede ser hasta infantil. *Alienae potestati subiectus* es, ante todo, el *filius familiae*, descendiente legítimo o adoptivo de un *pater* que vive, sin ningún límite de edad; en segundo lugar, la mujer que al contraer matrimonio se ha sometido a la *manus*, como es esencial en el derecho más antiguo y como todavía excepcionalmente se practica hacia el fin de la República y en los primeros siglos del Imperio; en fin, las personas *in causa mancipii*, hombres libres que por razones especiales, sobre todo a causa de delitos cometidos o en garantía de obligaciones del *pater familias* de quien dependían, han sido trasferidos a extraños en situación cuasi servil.

Las consecuencias de la pertenencia a la familia en calidad de persona *alieni iuris* son, en cierto sentido, opuestas a aquellas a que conduce la falta de la *civitas*: mientras, en efecto, el no ciudadano es favorecido lo más posible (a través de todas las reglas particulares de que se ha hablado) en las relaciones de derecho privado, pero rigurosamente excluido de toda relación de derecho público, los hijos de familia y los hombres *in causa mancipii* son equiparados a los *patres* en el *ius suffragii* y en el *ius honorum*, y están, en cambio, privados de capacidad jurídica patrimonial. Tanto es así que, por lo menos en la época republicana, rigen uniformemente para todas las personas *alienae potestati subiectae*

las reglas ya examinadas para el esclavo (p. 56): toda adquisición del sujeto a potestad entra automáticamente en el patrimonio del *pater*; todo contrato del sujeto a potestad crea, para él, una obligación simplemente natural (desprovista de acción judicial), y sólo en casos particulares es concedida al tercero una acción contra el *pater*; éste puede conceder al sujeto a potestad un *peculio*, pero sólo de hecho, mientras jurídicamente los bienes permanecen en su patrimonio.

Pero mientras con relación al esclavo estas reglas han permanecido en vigor en todas las fases del desarrollo del derecho romano, respecto de los sujetos a potestad libres (y de los hijos de familia en particular) se han ido modificando. Así, al lado del *peculium* propiamente dicho, no distinto al del esclavo, se llegó a admitir desde la época de Augusto un *peculium castrense*, que comprendía los bienes adquiridos en el servicio militar, considerado como patrimonio propio del *filius familias*, que puede hacerlo objeto, tanto de actos de disposición entre vivos como de testamento; bajo Constantino fueron equiparados al *peculio castrense* los bienes adquiridos en los oficios civiles (*pec. quasi castrense*), y alrededor de la misma época se consideraron como propiedad del hijo de familia todos los bienes que él hubiera recibido en herencia o donación (*bona adventicia*), reservándose al padre sólo el usufructo. Igualmente se había llegado, ya hacia el fin de la República, a considerar al hijo de familia como posible deudor de obligaciones civiles, salvo que éstas sólo se hacían exigibles a la muerte del padre o cuando, de otra manera, el hijo se hiciera *sui iuris*. Análogamente se desarrolló, también, la capacidad del hijo de familia para ser parte en procesos privados.

## § 6. CAUSAS DE DISMINUCIÓN DE LA CAPACIDAD JURÍDICA

- 1) *Infames*; 2) *addicti y nexi*; 3) *auctorati*; 4) *redempti ab hostibus*. — 5) La religión como causa de disminución de la capacidad: tolerancia pagana e intolerancia cristiana. — 6) Clases, estados, profesiones: en particular, transmisión hereditaria de los oficios y colonato en el derecho posclásico. — 7) Limitaciones en razón del sexo. — Capacidad de obrar.

Independientemente de las reglas que se vinculan a los *status*, el derecho romano conoce varias situaciones que sustraen al sujeto

alguna parte de su capacidad jurídica, limitando, de cualquier modo en su desventaja, la esfera en que normalmente puede ejercitarse la libertad de acción del particular. Cada una de estas situaciones es propia de una u otra época, o asume en los distintos períodos modalidades diversas.

1) En el concepto de *infamia* se comprenden varias instituciones del derecho antiguo. Con él suele vincularse, erróneamente, la pena que en las XII Tablas se establece contra quien, habiendo actuado como testigo o *libripens* en un negocio jurídico, se rehusa a testimoniar en el momento de la eventual controversia cuanto ha ocurrido bajo la acción de su vista: la sanción está expresada con las palabras *improbis intestabilisque esto*, y en ella se suele ver, además de la incapacidad para testar y para actuar como testigo (*intestabilis*), también una exposición al público desprecio como hombre malvado (*improbis*)<sup>18</sup>. Más exactamente se vinculan con el concepto de infamia los casos en que un ciudadano es alcanzado por la *nota censoria*; es decir, aquellos en que, en el actq del censo, el magistrado, teniendo en cuenta los antecedentes políticos o privados del ciudadano, lo excluye de la lista de los *senadores* o lo traslada de los *equites* a los *pedites*, de una clase más elevada a otra inferior. Y así también el ciudadano alcanzado por la *nota consular*, es decir, el que presentando su candidatura a cargos públicos la ve rechazada por el cónsul en ejercicio (*nomen non recipere*). Sin embargo, no tiene lugar, en estos casos, una limitación propiamente dicha de la capacidad jurídica, y menos aún en el terreno del derecho privado. Una limitación de la capacidad por razones morales existió cuando algunas categorías de

<sup>18</sup> La interpretación es probablemente errónea: *improbis esto* = sea maldito no podría ser una sanción jurídica. Una tardía glosa griega (citada por MANICK, *Enciclopedia* de PAULY y WISSOWA, voz *Intestabilis*), que traduce *improbis intestabilisque* con ἀδόκιμος καὶ ἀπίστυτος, nos da, en mi opinión, la clave del enigma. En los documentos que se refieren a los pagos la moneda toma el nombre de *proba*, es decir, verificada como buena, resistente a la prueba. Ahora bien; esta *probatio* (δοκιμασία) se confundía, cuando la moneda no era todavía acuñada, con la pesada del *aes rude*, y era, en consecuencia, función propia del portador de la balanza, *libripens*. Ser *improbis* quiere decir no poder ya *probare*, es decir, quedar excluido para lo futuro de la función de *libripens*, como ser *intestabilis* expresa, en los orígenes, nada más que no poder ya hacer de testigo. Así se observa en ellos la pena del tallón. Diversa tentativa de interpretación en WENGER, *Istituzioni di diritto processuale civile romano*, p. 188, n. 30.

personas a quienes la opinión pública consideraba *ignominiosae*, fueron comprendidas en las cláusulas del Edicto pretorio que prohibían *postulare pro aliis*, es decir, representar a terceros en juicio. En la lista quedaron comprendidos los hombres<sup>10</sup> que hubiesen ejercido oficios deshonestos, y entre éstos el arte teatral y la gladiatura; los bigamos; el que hubiese desposado a una mujer en segundas nupcias antes del año de la disolución del matrimonio, aunque lo hiciese con el consentimiento del padre de ella; los condenados por delitos públicos, y también por algunos delitos privados; en fin, los condenados en los procesos civiles de depósito, de *fiducia*, de mandato, de sociedad, de tutela. Pero aunque la sanción edictal partiera de una reconocida *ignominia*, ni esta palabra ni otra equivalente figuraba en el Edicto, que se limitaba a establecer las prohibiciones citadas (cfr. GAYO, IV, 182); sólo JUSTINIANO, trasladando al Digesto la cláusula edictal *qui pro aliis ne postulent* (D. 3, 2, 1), ha llamado *infames* a los alcanzados por las sanciones pretorias; antes bien, ha inventado el nuevo rubro "de his qui notantur infamia".

Aparte del efecto ya señalado, la infamia produce también otros que derivan, sin embargo, más de la discreción del magistrado que de normas generales. Así, puede ser declarado inaceptable el testimonio de un infame; puede ser facilitado el ejercicio de la *querela inofficiosi testamenti* a los parientes cercanos que se hayan visto postergados por un infame; y entre varios tutores testamentarios son preferidos como administradores efectivos los no infames, aunque los infames estén dispuestos a dar caución y los otros no. Precisamente porque son en gran parte discrecionales, estas sanciones pueden ser aplicadas a personas que no pertenezcan a la lista de los infames pero que ejercen oficios equívocos o repugnantes (*personae turpes*), por ejemplo, los *praecones* (pregoneros públicos), los *circitores* (mercaderes ambulantes), los *libitinarii* (sepultureros), etc.

2) Una situación que pertenece exclusivamente al derecho más antiguo es la de los *addicti*. En ella caen los deudores contra quienes se ha iniciado el procedimiento de la *manus iniectio* (infra, p. 127): el deudor *addicebatur* por el magistrado al acreedor,

<sup>10</sup> Las mujeres estaban excluidas, como tales, del *postulare pro aliis*: pero en las categorías correspondientes a las catalogadas, también ellas eran consideradas *ignominiosae* para todo otro efecto.

que antes de matarlo o de venderlo lo mantenía sesenta días en su cárcel privada. Análoga es la posición de los *nexi*, deudores o personas en potestad del deudor, que se dan o son dadas en prenda al acreedor con la facultad (parece) de obtener rescate mediante la prestación de servicios (cfr. *infra*, p. 357). Mientras permanecen tales, los *addicti* y los *nexi* son libres y ciudadanos, pero sufren las limitaciones de la libertad que derivan de la disponibilidad concedida al acreedor sobre su persona.

3) Afín es también la posición de los *auctorati*, hombres libres que han alquilado sus servicios a un empresario de combates de gladiadores (*lanista*) con el juramento de dejarse *urere, vincere, necare*. También ellos permanecen libres y ciudadanos; pero aparte de incurrir en la infamia de que ya se ha hablado, están en condición cuasi servil; tanto es así que quien los sustrae al empresario comete hurto, como quien sustrae una cosa a otro, y que GAYO usa a su respecto la característica expresión *auctoratus meus* (III, 199)

4) Análoga es, en fin, la situación del *redemptus ab hostibus*, ciudadano a quien otro ha rescatado de la prisión de guerra; pesa, en efecto, sobre él, según la expresión de los textos justinianos, un *vinculum pignoris*, en virtud del cual está obligado a servir al *redemptor* hasta cubrir el importe de la suma pagada en rescate, o —según una constitución de Arcadio y Honorio— por cinco años<sup>20</sup>.

5) La *religión* no representa, en el más antiguo derecho romano, una causa de reducción de la capacidad jurídica. El politeísmo de los pueblos clásicos hace que con los dioses conocidos y adorados por cada ciudad o gente puedan coexistir infinitos otros, propios de otras ciudades o gentes, y que los cultos sean comunicables de país a país. Por lo que no debe extrañar que, en la guerra, los romanos intentaran aplacar a los dioses del enemigo ofreciéndoles sus sacrificios y votos, y que al extenderse el Imperio se acogieran en el mundo romano gran número de dioses y cultos, desde la recepción de las divinidades griegas hasta la verdadera invasión de los cultos asiáticos que tuvo lugar bajo los Severos.

<sup>20</sup> Para la historia de la institución (que sería la atenuación de una norma establecida en la segunda mitad del siglo II d. C., por la cual el *redemptus* se hacía directamente esclavo del *redemptor*), ver LEVY, *Captivus redemptus*, en "Class. Philology", 38, 1943, ps. 159 y ss.